

行政命令的抽象司法審查*

— 以法國法為中心

王必芳**

目 次

壹、前言	一、原型：針對命令提起越權之訴
貳、行政行為的法制度	二、變型：針對拒絕提起越權之訴
一、行政行為的界定	
二、越權之訴的客體	
參、行政命令與司法審查	伍、反思與展望
一、命令與法律之間關係的變遷	一、分析／比較／檢討
二、命令違法審查的範圍和途徑	二、我國建制行政法院命令抽象審查機制之初探
肆、行政命令與抽象審查	

* 投稿日：2011年8月9日；接受刊登日：2012年2月3日。〔責任校對：簡蔓婷、蔡秉錡〕。

本文構想曾於2010年12月中研院法律所憲法組群成果發表會中提出，感謝劉淑範和吳秦雯兩位先進惠賜寶貴意見。本文初稿發表於2011年3月個人學術研討會，撰文期間和會議中，承蒙黃丞儀等多位同仁指教，作者獲益良多。最後，衷心感謝兩位審稿人細心指正。

** 中央研究院法律學研究所助研究員。

摘 要

行政訴訟制度之目的為何，學說上有「權利保護說」與「合法性控制說」之爭。德國模式是以前者為核心，法國模式則是後者的代表。對於法國行政訴訟制度的特點，我國學界都聚焦在其對於起訴能力和訴之利益的要求較為寬鬆上，似乎並未注意到在其維護行政合法性的主要管道——「越權之訴」(recours pour excès de pouvoir)中，可得爭訟的違法行為，其實包括行政機關所有的單方行為，亦即，除個別行為外，還包括行政命令在內。在法國，行政法院對於行政命令所行使的抽象審查，被認為與行政命令的具體審查之間具有互補而不可取代的關係，且其得導致違法命令自法秩序中徹底消失，可謂是法國模式在維護客觀法秩序上最極至的展現。在我國，有關命令違法的控制機制，在設計上和運作上不乏改善的空間。本文主張以法國模式作為另一個反思的起點，並於考量到我國現行行政訴訟制度之架構以及司法資源下，適當地開鑿行政法院介入的管道，以擴張其維護客觀法秩序的功能，或許可以作為考慮的選項。

關鍵詞：行政命令、行政訴訟、抽象司法審查、法國行政法、越權之訴。

Judicial Review of Administrative Rules: From the Perspective of French Law

*Pi-Fang Wang**

Abstract

As far as the guiding principle of the administrative litigation is concerned, different views are expressed between the objective of “protection of rights” and “legality control”. If the German system can be said to place its focal point on right protection, the French system presents a case which operates around the idea of controlling the legality of administrative acts. Past discussions in Taiwanese academic communities have noticed features of French administrative litigation system such as its general criteria with regard to the capacity of bringing a suit and the interest protected by the actions. What seems to be overlooked, however, is that as for the primary means of legality control in French system – *le recours pour excès de pouvoir* –, the actionable objects extend to all types of administrative acts unilaterally made by public bodies, that is, the object of actions covers not only the specific administrative decisions, but also the administrative rules. In the French system, the court’s abstract review of administrative rules plays an irreplaceable and complementary part for its concrete review of administrative rules. Further, the abstract review might lead to the annulment of the rules, once found illegal, and by this it will have the effect of eradicating those rules from the French legal order. In this sense, the abstract judicial review of administrative rules represents the ultimate authority exercised by the judiciary in guarding the objective legal order. From such a perspective, the mechanism of illegality control with regard to administrative rules and regulations in Taiwan, in terms of

* Assistant Research Professor, Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica.

its design and operation in practice, has some room for improvement. In this respect, the French model serves as a starting point for reflecting on the possibility of creating a role for the administrative courts in fulfilling the function of maintaining the objective legal order in the Taiwanese system, taking into account the current structure of the administrative litigation in Taiwan and resources available to the judiciary. This paper argues that such an approach is an option worth consideration.

KEYWORDS: administrative rules, administrative litigation, abstract judicial review, French administrative law, *recours pour excès de pouvoir*.

壹、前言

行政訴訟制度應依據何種目的而運作，不僅與訴權理論的建構，也與立法政策的設計、現行法制的解釋等問題息息相關，學說上有「權利保護說」與「合法性控制說」之爭¹。在德國行政訴訟制度形成的歷史過程中，「主觀公權利保障模式」及「客觀法秩序維護模式」均有其支持者，也各自曾獲得某種程度的實踐。惟二次大戰後，人性尊嚴的維護成為憲法最高價值，德國基本法第19條第4項規定：「任何人權利若受公權力之侵害者，得向法院請救濟」，自此確立了以人民權利保障為行政法院核心功能的基調²。

而法國行政訴訟制度，雖愈來愈強化其保護權利的面向，但仍可謂是客觀法秩序維護模式的代表。我國行政訴訟制度深受德國的影響，不過國內學者不無注意到法國模式者，除蔡志方教授早於30年前相當完整地介紹法國行政救濟制度外³，較新近者，例如陳英鈴教授在談論行政訴訟的訴權類型時，於區別德國和法國分屬被害人訴訟和利害關係人訴訟之代表後，另強調：「法國法寬鬆與彈性訴權認定，對於我國是否往客觀法律維持的訴權邁進，提供了另類思考的空間」⁴；而林明鏘教授在其研究歐盟行政法的專書中，除提及德國行政訴訟之目的在於「有效保護個人權利」，與法國法上以「維護公益為目的」之訴訟大不相同外，亦指出「德國行政訴訟制度受歐盟法衝擊最大的反思之一即是：完全以個人主觀權利維護

1 詳參劉宗德、彭鳳至，行政訴訟制度，收於：翁岳生編，行政法（下），3版，頁355以下（2006年）。

2 參見盛子龍，第1條 立法宗旨，收於：翁岳生編，行政訴訟法逐條釋義，頁25以下（2002年）。

3 蔡志方，法國行政救濟制度研究（上），憲政時代，7卷4期，頁28-46（1982年）；蔡志方，法國行政救濟制度研究（下），憲政時代，8卷4期，頁59-82（1983年）。

4 陳英鈴，撤銷訴訟的訴權——個人權利保護與法秩序維護之爭，收於：台灣行政法學會編，行政法爭議問題研究（下），頁984、991（2000年）。

為主軸的權利保護體系，是否應增加其他大部分歐盟會員國之客觀公益維護訴訟類型問題」⁵。

然而，我國學界對於主要透過「越權之訴」(recours pour excès de pouvoir)確保行政合法性的法國模式，多聚焦在其對於起訴能力和訴之利益的要求較為寬鬆上，似乎未注意到，其在維護客觀法秩序上最極致的表現其實在於：可得爭訟的行政行為(acte administratif)，不限於個別行為（相當於我們所稱的行政處分），還包括行政命令(règlement administratif)在內⁶。當然，行政命令可以成為法院附帶審查的對象，可謂是各國的通例，但並非在所有國家的行政訴訟制度中都存在著以主要名義爭議行政命令的管道，在我國即是如此。對於行政命令的直接訴訟，無疑要以法國以及一些追循其榜樣的國家，最為發達；但有些側重主觀公權利保護的國家，

5 林明鏘，歐盟行政法——德國行政法總論之變革，頁222、251（2009年）；並參見Wolfgang Kahl著，林明鏘譯，德國與歐盟行政法上主觀公法上權利之現況、演變及其展望，臺大法學論叢，40卷2期，頁877以下（2011年）。

6 試究我國學界忽略的原因，若非出於有意，或許是對法國法上之「行政行為」(acte administratif)有所誤解。我國所稱之「行政處分」概念，德文為Verwaltungsakt，若直譯即為行政行為，依陳敏教授的說明，此用語係由「Otto Mayer翻譯自法文之『acte administratif』……原泛指各種依據公法或私法之行政措施。惟在德國之『Verwaltungsakt』一語，自Otto Mayer引進伊始，即限定於公法領域之行政措施。依德國現行政程序法第31條第1句之定義規定，行政處分係『行政機關在公法領域上，為規制個別事件，以直接對外發生法律效力為目的，所為之各種處置、決定或其他之公法措施』。此一行政處分之概念，與Otto Mayer所賦予之內涵，並無出入。我國繼受大陸法系行政法，所採用之行政處分概念，與德國並無本質之不同」（陳敏，行政法總論，7版，頁294（2011年））。然在法國，學說雖對acte administratif採取不同觀點，但實務自19世紀中葉起即逐步將全體行政命令含納在內，作為行政訴訟的客體。可見，acte administratif在引到德國後，不僅被限定於「公法領域」，且未擴及到一般性的法規範。我國學者在透過德文或其他外文文獻理解法國法時可能未察，也因此忽略了最能彰顯法國行政訴訟制度之客觀特徵的部分，亦即，得直接針對命令提起撤銷訴訟。例如，蔡志方教授在其大作中有些語意不詳地表示：「撤銷之訴為對違法之行政處分(acte administratif illégal)有關之一切事項所提之訴……。越權訴訟……主要在於維繫公權秩序及對合法性之尊重……，原則上係對行政處分為之，但對個別行為或法律行為亦有效……」。參見蔡志方，法國行政救濟制度研究（下）（註3），頁65。

如德國，亦承認此一管道，只是是以有限的方式承認之。我國學界並未忽略德國行政法院法第47條的「規範審查程序」，並有倡議為貫徹行政合法性、維護公共利益，在立法政策上也有承認諸如民眾訴訟或規範審查程序等特殊之客觀訴訟類型的餘地⁷，甚至有進一步針對行政機關怠於或拒絕制定法規命令，探討是否在行政訴訟法上承認「規範制定之訴」⁸。

在法國，行政命令的抽象審查屬於行政訴訟中極為通常的一環，以致於現今一般有關行政法或行政訴訟法的著述中，不會將命令的審查問題特別獨立出來處理，更不會追溯其來源。然觀諸整個法國行政訴訟制度的架構和歷史可發現，此一機制的出現和發展，實有其脈絡可循，且即使在第五共和下命令與法律的關係發生變化，亦未能動搖之。有鑑於其原初性⁹和完備性所呈現出的比較法研究上的意義，本文擬以之作為主題，並期能藉此增進國內對於行政訴訟制度中客觀法秩序維護模式較為全面的掌握，甚或對於我們頗為困擾的違法命令控制問題提供另類的啟發。考量到國內對於作為本文研究基礎的法國行政法和行政訴訟制度較為陌生，若直接切入並嚴格扣緊主題，恐無益於理解，故本文將以漸進方式，先綜觀與主題相關的法國行政行為的法制度（貳）以及行政命令的審查權限、範圍、管道（參），以之為基礎，再行探究其命令的抽象審查機制（肆），最後並以淺評此一機制以及試探其在我國的發展空間作為總結（伍）。

7 如陳清秀，行政訴訟法，4版，頁156（2011年）；林明鏘（註5），頁252。

8 盛子龍，行政訴訟法上「請求法規命令制定之訴」初探，收於：翁岳生編，當代公法新論（下），頁193以下（2002年）；程明修，請求行政機關訂定法規命令之行政訴訟，收於：司法院編，行政訴訟制度相關論文彙編（第5輯），頁125-174（2005年）。

9 在德國，舊行政法院法(VGG)第25條對於美國佔領之範圍已有類似之法規程序，現行的抽象法規審查係參照當時適用於南德各邦之有效規定所制定。參見Erich Eyermann著，陳敏等譯，德國行政法院法逐條釋義，頁472（2002年）。由於南德各邦的行政訴訟制度原受法國影響，本文推測德國現行之法規審查程序亦受其啟發。

惟須先指出，法國現已擁有一部行政法院法典(Code de justice administrative)，彙集所有有關行政法院之組織和運行的法則，但有許多行政訴訟的重要原則或發展動向，是由其最高行政法院(Conseil d'Etat：以下或稱諮政院)¹⁰所建構或引領，本文將直接援引其相關判決以資說明。此外，本文所稱的行政命令(或簡稱命令)是指行政機關，或基於法律授權，或基於職權，就一般性事項，所訂定發布的抽象性規範¹¹。至於「抽象審查」(abstract review)，是相對於「具體審查」(concret review)而言，凡法院得專就命令有無違反上位規範進行審查，並無須附隨於具體訴訟案件而為者，即為抽象審查；反之，法院僅得於審理具體案件或爭議時，一併審查其間適用之命令有無違反其上位規範者，為具體審查。抽象審查有其獨立程序，實為「主要審查」(review principaliter)，而具體審查並無特殊程序，屬「附帶審查」(review incidenter)¹²。

10 Conseil d'Etat設立於18世紀末，為方便理解，本文譯為「最高」行政法院。但法國的行政法院系統是在1950和1980年代分別設立地方和上訴行政法院才三級化，因此Conseil d'Etat在做成以下所引之諸多裁判時，還不是名符其實的「最高」行政法院。另，Conseil d'Etat除有具訴訟部門外，並設有數個諮詢部門對於政府準備法律或重要命令之草案等提供意見，當其扮演此一角色時，本文稱為「諮政院」。

11 此定義採葉俊榮，行政命令，收於：翁岳生編，行政法（上），3版，頁391（2006年）。此一定義大致與法國之règlement administratif相當。惟在法國，行政命令的分類方式與我國不同，見參、一；且行政機關的抽象性規範中，有些不被認為具備命令的特徵，如部分的通令（類如我國所稱行政規則中之行政釋示、裁量性準則等）和服務之內規（類如我國所稱特別權力關係中之特別命令），見貳、二。

12 這是國內學者在比較違憲審查制度類型時所提出的分類和定義，參見湯德宗、吳信華、陳淳文，論違憲審查制度的改革——由「多元多軌」到「一元單軌」的改制方案，收於：湯德宗編，憲法解釋之理論與實務（第四輯），頁535（2005年）。因與法國學說在處理命令違法審查問題中所使用的用語和分類相符，本文借用之。

貳、行政行為的法制度

在法國，行政職能(*fonction administrative*)最顯著的面向之一在於，為實現此一職能所為之法行為是適用統一的法制度，亦即，全體的行政行為，不論其作者或其介入之事項，均遵守相同的合法性，且臣服於相同的司法審查。在此架構下，有關行政命令的司法審查，並非仿效另一種非屬人行為——亦即法律——的審查方式；相反地，其特點主要表現為：一方面，對於違法命令，得透過起訴途徑使其自法秩序中消失；另一方面，在主要方向上，其與個別行為之審查間並不存在特別的差異處。從法國學說是以整體方式來評介行政行為之理論和越權之訴之理論，足以印證此一特點¹³。

一、行政行為的界定

不同於私人間的法律活動是以意思合致作為通常的方式，行政活動中最典型的手段是行政機關透過單方意思去修改法狀態而無庸利害關係人的同意，學說一般而言將此一手段稱為「行政行為」¹⁴。然而，行政行為雖是行政法上一個非常基本的觀念，其定義卻不如想像中明確。學者間依其對行政行為所採的觀點不同，而有不盡相同的定義。依據André de Laubadère, Jean-Claude Venezia, Yves Gaudemet所歸納出的形式、實質、功能三種觀點來看¹⁵，在法國，行政行為之界定是以形式觀點占上風，且與行政法院的審判權限有緊密的聯結。

13 有關法國行政職能的統一性，參見DE BECHILLON (D.), *Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l'Etat*, Paris, Economica, 1996, p. 104 et s.

14 除「行政行為」(*acte administratif*)外，學者間尚有使用「單方行政行為」(*acte administratif unilatéral*)、「決定」(*décision*)、「單方決定」(*décision unilatérale*)、「決定性行為」(*acte décisoire*)、「執行性決定」(*décision exécutoire*)等用語。參見DE VILLIERS (M.) (dir.), *Droit public général*, Paris, Litec, 2003, p. 591.

15 以下有關行政行為的三種觀點及其分析，主要參照DE LAUBADERE (A.), VENEZIA (J.-C.) et GAUDEMET (Y.), *Traité de droit administratif*, t. I, 13^e éd., Paris, LGDJ, 1994, pp. 535-552，不再個別引註；至於其他補充之資料來源，將在各別註腳中指出。

(一) 以形式觀點為主

由於法國成文法並未賦予行政行為單一和明確的定義，學說對於行政行為有分歧的界定方式，主要有實質觀點和形式觀點的古典爭論。實質觀點首要關注的是行為的客體和目的性，形式觀點則著重在機關的要素以及行為的功能、權威和可爭訟性。

根據由Léon Duguit所發展的實質觀點，國家職能的區別應建立在法行為的一般分類之上，亦即，建立在具一般拘束力的行為和具個別拘束力的行為的區分之上。此種觀點將導向行政行為與立法行為之間的對立，前者是僅具個別拘束力的行為，後者是具一般拘束力的行為。此種定義方式，其實頗符合「法律是抽象的和一般的法則」此一最為傳統的觀點。由於立法職能在於形成法則，立法行為因此是所有一般的、抽象的、非屬人的、必然是由國家所制定的規定；相反地，行政職能在於作成個別的決定。在此視角下，命令將向法律靠攏，構成實質上的立法行為。

無可否認的，基於其所呈現的一般性特徵，在法國法上有時將行政命令與形式法律等同對待，例如普通法院對於命令所擁有的解釋權限、命令在合法性來源中所占的地位等等，而權限爭議法院(Triubnal des conflits)亦於1923年的Septfonds判決中指出：「……若基於其所出自之機關的特徵，命令構成一行政行為……其亦具有立法行為之特徵，因為其包含著一般性和規制性層面的規定」¹⁶。此外，在法國法上，出自行政機關的行為，還依據其是行政命令或是個別行為，而分別被賦予一些不同的效果。這些差異特別是涉及到行為的制定程序、說明理由的義務、其生效和撤回的要件，另外，亦與訴訟期間的起算、違法性抗辯的管道、初審的管轄法院等等問題息息相關。這些設計或許不能夠完全透過命令與法律間的近似性

16 TC 16 juin 1923, Septfonds.

來加以說明，卻顯示出具一般拘束力之行政機關行為所具有的特殊性。

不過，實質觀點雖不無其立足之處，卻遭受到大多數法國學者的爭議。以Raymond Carré de Malberg為首的「形式主義」學派認為，國家的職能僅能依據行使職能的機關來作區別，因此，所謂的行政行為是指出自於行政機關的行為。此一論點既將行政行為定義為由國家之行政機關所作成的所有行為，其研究的重心即置於追究哪些機關具有行政機關的資格？哪些機關是屬於立法的或司法的機關或僅是單純的私人機構？支持形式主義觀點的主要論據是，法國的實證法僅考量到國家行為的形式性質。若以實證法為考察對象，可發現，形式觀點的確表現出無可爭議的重要性。

首先，由國會作成的個別措施，雖然屬於實質上的行政行為，卻仍適用所有屬於形式意義之法律的法制度，特別是不能被法院撤銷。相反地，行政命令雖有時被呈現為實質的立法行為，其形式上之行政行為的性質足以將其自法律的法制度中抽離，而使其臣服於行政行為之制度。因此，不同於形式上的立法行為，所有行使公權力之執行部門的決定，不論具個別的或一般的特徵，都從屬於相同的行政法制度，於此，個別行為和行政命令的區別不是基本的，所有形式上的行政行為都服從於相同的法院控制，且特別是，當其具有法效果時，得透過越權之訴的管道請求撤銷。另應提及的，在形式觀點的邏輯下，只有單方行政行為得被視為是真正地出自於行政機關的行為，至於行政機關和個人所簽訂之契約，因包含兩個意思的協力（行政機關的意思只是其中之一），因而在習慣上並不被認為屬於狹義的行政行為。

雖然在法國，行政命令和個別行為的區分相當清楚¹⁷，然此區

¹⁷ 有些行政機關的行為既不是命令，亦不屬於個別行為或個別行為的集合，稱為「個案決定」(décisions d'espèce)，又稱為「特別行為」(actes particuliers)或

別對於法制度的影響十分有限。在界定行政行為上，二者的區別似乎僅能在次要的層面上介入，亦即，在以形式標準為特徵的行政行為類別中，作為一個次要的區分要素。

(二) 與行政訴訟連結

在法國，形式觀點在行政行為的界定上扮演著優勢的角色，但隨著行政機關行動方法的演進，再加上同時須辨識出審理此等行為的法官，問題變得較為棘手。觀察判例可發現，在定義行政行為時不能忽略的問題是：此行為是否屬於行政法的範疇，且當發生訴訟時，是否屬於行政法院的權限。在此思考脈絡下，有另一種觀點主張，對於行政行為的界定，首要在於知道：此行為是否屬於行政法和行政訴訟權限的行為。此一觀點稱為功能觀點(*conception fonctionnelle*)，其並不以行為的形式的或實質的定性作為判斷的標準，而是將一些支配行政法院和普通法院間權限分配的一般性標準——結合了機關的條件和行為的特徵——，適用於行為的領域中。

這些標準的適用，為行政行為之觀念帶來修正和補充。首先，若依純粹的形式觀點來看，舉凡出自公法人的單方行為，依定義，都是行政行為，但自功能觀點來看，則不全然如此。行政機關所為之私管理行為即被排除在外，而被歸類為屬於私法範疇和普通法院權限的行為。其實，在19世紀初即萌發以下理念：一方面，組成行政機關之公法人有其專有的活動，而基此理由，應從屬於特殊的制度；另一方面，存在著一些並無不同於私法人活動的活動，而基此理由，應臣服於普通法的制度。此理念被延續下來，構成錯綜複雜

「中間行為」(*actes intermédiaires*)，是與某一情況或一特殊活動有關的行為，例如為某特定選舉而召集選民，開啟競試或訂定測試日期、在徵收程序中宣告活動具公共效用等。這些行為依情況適用個別行為或行政命令之法制度。詳見 CHAPUS (R.), *Droit administratif général*, t. I, 15^e éd., Paris, Montchrestien, 2001, p. 527 et s.

的因素，因為一旦轉入到行政機關活動的內部，行政制度必然取決於這些活動的性質或方式，形式的或機關的標準即不再足夠。其次，一些先天上不能構成形式上之行政行為的私法人行為，卻有可能被視為是行政行為。自二次大戰後，一些私組織（特別有關職業紀律和統制經濟之組織）開始擔負起公共服務之使命且被授予制定單方措施之權限，當其所作成之一般性或個別性的單方行為與執行公共服務有關、且蘊含著公權力之行使時，這些行為亦被認為屬於行政法院的審判權限，且以此名義，構成行政行為¹⁸。

如同De Laubadère, Venezia, Gaudemet所指出的，在上述行政行為的不同觀點間，其實存在著相互補充而非競爭的關係，每一觀點各有其理論和實務的價值。惟應強調的是，在法國，行政行為之觀念遠非是一個純粹理論研究的課題，而是傳統上一個務實取徑的客體。在採規範和裁判二元主義的法國，行政法的適用若發生糾紛，幾乎是落入行政法院專有的權限範圍內，後者為了劃定其權限，必須去質問行政制度的正確輪廓。即便最高行政法院的裁判有時令人難以理解或相互矛盾，但學說很自然地是透過對這些裁判的比較和體系化，推導出一些有關行政制度之說明性要素和原則。因而，尋找行政制度的一般標準是以弔詭的方式進行，亦即基本上是行政法院的權限空間決定了行政制度的範圍¹⁹。也因此，在法國，對於行政行為輪廓的勾勒，總是與訴訟相牽連(implications contentieuses)。在此問題上，成文法所提供的幫助十分有限，實際上是歸由法官來對此等行為與其他的國家行為或私法行為進行區別。換言之，行政行為是「被訴訟所揭露的」，依法官接受或拒絕受理哪個行為而勾勒出行政行為的邊界。如此一來，行政行為幾乎是自動地被視為是

18 CE 13 janvier 1961, Magnier; TC 15 janvier 1968, compagnie Air France c. époux Barbier.

19 有關行政法院的權限和行政制度的關係，參見DE LAUBADERE (A.), VENEZIA (J.-C.) et GAUDEMET (Y.), (註15), pp. 33-34.

由行政法院所控制、且在此意義下免除其明確特性的行為²⁰。

在行政行為與行政法院權限的自動聯結下，有學者將（單方）行政行為直接定義為「得透過越權之訴的管道向法院爭議的行為」。此定義是可操作的，但不乏批判的空間，因其並未解決而僅是推移真正的問題：何為得提起越權之訴的行為²¹？

二、越權之訴的客體

在法國，行政命令和個別行為的區別，沒有對訴訟制度造成影響，司法審查不因行為的性質而有所變化。在行政訴訟上，對於行政機關行使其首要權力——制定行政行為——的合法性控制，共通的手段是越權之訴。越權之訴是法國行政法上最具特色、也是最重要的制度之一，不但構成某種「安全閥門」，更是「置於所有人手中用以防衛被漠視之合法性的工具」²²。然而，何為得以透過越權之訴爭議的行為？由於法官是依據個案作出宣告並未樹立起通行的標準，因此，答案並非如此明確，依學說的分析，有些行為基於其效力或特性而被排除在外。

（一）越權之訴的特徵

在法國，對於行政合法性的控制，有行政和司法兩種互補的方式，除非有成文法的特別規定，否則並無訴願前置的要求，亦即可直接提起越權之訴。相對於行政控制而言，司法控制是後來才出現，且是由前者衍生出來。要知，在1872年5月24日法律正式賦予最高行政法院以法國人民之名義直接審判之權力以前，最高行政法

20 Cf. CAPELLE (C.), *Acte administratif et justice administrative en Europe*, *RFDA*, 2008, p. 258.

21 DUPUIS (G.) et GUEDON (M.-J.), *Droit administratif*, 4^e éd., Paris, Armand Colin, 1993, p. 386.

22 分見Aucoc, concl. CE 13 mars 1867, Bizet et Pichat, concl. CE 8 mars 1912, Lafage, cités par PACTEAU (B.), *Contentieux administratif*, 7^e éd., Paris, PUF, 2005, p. 208.

院的任務僅是為國家元首準備草案和作出提議，再由元首以自身名義作成最後決定。因為元首依據其上級監督權，理當可以撤銷行政機關的決定，因此，此時的越權之訴實具有向上級機關提起之「階層訴願」(recours hiérarchique)的性質，爾後隨著行政法院獨立審判，越權之訴才漸進成為真正的行政訴訟。由此不難理解到，此一救濟管道一開始是被構思為確保行政機關的良好運作，而較不是為了給予私人有效保護，此一來源亦說明了其所具有的客觀特徵²³。

傳統上，越權之訴被分類在客觀訴訟中，由此理解到其所涉及的不是單純兩造間的訴訟，而是針對「行為」所提起的訴訟：請求人被視為是為了將違法行為自法結構中清除，而採取法律行動。換言之，這是一個保護客觀法的程序，與德國撤銷之訴(Anfechtungsklage)旨在保護主觀權利迥異。因為客觀法或合法性是屬於所有人的福祉，René Chapus教授將越權之訴稱為「公共效用之訴」(recours d'utilité publique)。即使請求人認為自己是為了自身利益而自私地行動，其真實的身分是合法性的防衛者或是「法的檢察官」，其所履行的是公共職責，亦即對行政機關進行控制。相對地，法官撤銷違法行為，與其說是為了修復請求人的損害，毋寧是為了重建被違背的合法性²⁴。

23 Cf. FROMONT (M.), *Droit administratif des Etats européens*, Paris, PUF, 2006, p. 163 et s. 在法國，行政訴訟的古典分類是由Lafférière在19世紀提出，其依法官手中所握有的不同權力區分完全訴訟 (contentieux de pleine juridiction：法官得修正和改造違法行為，除契約和責任之訴外，還包括選舉訴訟)、撤銷訴訟 (contentieux de l'annulation：法官限於撤銷違法行為，如廢棄之訴、越權之訴)、解釋訴訟 (contentieux de l'interprétation：限於單純的確認)和制止訴訟 (contentieux de la répression：得抑制違法行為)。其中以完全訴訟和越權訴訟的對立最為重要。到了20世紀，Léon Duguit和Marcel Waline依據向法官所提出之問題而區分客觀訴訟(contentieux objectif)和主觀訴訟(contentieux subjectif)。前者提問的是合法性本身 (以越權訴訟為代表，亦包括解釋訴訟、判斷有效性訴訟、稅務訴訟、道路違規訴訟)；後者提問的是個人權利 (契約訴訟、行政責任訴訟)。其實，這兩種區分方式在相當程度內是重疊的。詳見PACTEAU (B.), (註22), p. 30 et s.

24 CHAPUS (R.), (註17), p. 788.

正因為越權之訴是一個公用效用之訴，應容許儘可能最大多數人能提起。這首先說明了在此訴訟中，原則上不適用律師強制原則，以避免因財務理由所生的阻礙。其次，這說明了行政法院大方地判斷訴之利益，只須有簡單的「被觸犯的利益」(*intérêt froissé*)即可，使得越權之訴有時幾近到了「民眾訴訟」(*action populaire*)的地步，不能果真施行的原因，是考量到法院的負荷能力。基於相同理由，越權之訴應得以被用來對抗儘可能最大多數的行政行為，依判例，除非法律有相反的規定，否則依據行政法之一般原則，得提起越權之訴對抗所有的行政決定²⁵。最後，因為越權之訴是一個公共效用之訴，其具有公序之性質，故不能放棄行使。總之，法國行政行為之審查機制的設計，較非著重於個人主觀權利的保護，而是以維護合法性之必要為重心²⁶。

就其演進的過程來看，法國行政法院的功能在於確保行政當局遵守法律。行政法院透過越權之訴檢視行政當局對客觀公法之法則的遵守，被比擬為廢棄法院（*Cour de Cassation*：普通法院系統中之最高法院）檢視實體法院對客觀私法之法則的遵守。學說因而論及行政法院的教學或紀律功能：重要的是行政機關是否正確地行動，請求人的具體命運並不重要²⁷。然應注意者，由於司法機關的固有職能是針對「權利」是否受侵害作成裁判，因此，學說一開始很難接受得僅針對「行為」是否違法提起訴訟。這是為何，即使到了1872年後，越權之訴仍或多或少被認為是一種具裁判形式的階層訴願。直到今天，雖然客觀之訴屬於真正的訴訟已獲得肯定，且越權之訴不論自實質或形式觀點來看都被認為構成全方位的訴訟，但其制度的某些特點或是行政法院進行審查時的膽識（有時令人聯想

25 CE 17 février 1950, Dame Lamotte.

26 參見CHAPUS (R.), (註17), p. 788. 有關越權之訴的爭論和發展，詳見BLANCO (F.), *Pouvoirs du juge et contentieux administratif de la légalité*, Aix-Marseille, Presses universitaires d'Aix-Marseille-PUAM, 2010, p. 55 et s.

27 Cf. FROMONT (M.), (註23), pp. 164-165.

到行政首長的態度)，仍可追溯到此救濟管道的起源²⁸。

(二) 不能爭訟的行為

在最高行政法院眼中，針對行政行為提起越權之訴是屬於一般原則，但有些行為因其本身不能引發損害或不滿，或被認為在本質上不能向法官爭議其違法性，而不能提起越權之訴。前者主要是涉及到廣義的「內部秩序措施」(*mesures d'ordre intérieur*)，後者則涉及到「政府行為」(*actes de gouvernement*)。

首先，依據判例的用語，可以透過越權之訴爭議的行為，除在性質上應是行政行為外，還應在法效力上構成一個引發損害或不滿的決定(*décision faisant grief*)。後一條件首先排除了準備措施（如意見、調查、提議等）以及執行措施（如通知、公告、單純提供訊息等），而所謂的「內部秩序措施」，則引發複雜的問題，須進一步說明。廣義的內部秩序措施的共同點在於其並非直接針對人民，而是以行政機關內部之安排和運作為目標的措施，主要可區分為：1)一般性措施，可再分為廣義的通令（除狹義「通令」(*circulaire*)外，還包含「訓令」(*instruction*)和「指令」(*directive*)在內），是行政當局向其下級指示何為法之狀態以及如何實施的一般性規定（如有關法令之解釋和適用、裁量權之行使等）；以及公共服務機構之內規（如有關學校裡時間的分配、服裝的管理等）。2)個別性措施，是上級針對某個公務員所下達的特殊訓令，以及針對公務人員或與公共服務有關者所作之各種措施（如對軍人之懲處、供應商之排除、對於公共服務之使用者所作成之決定等）。有鑑於其「內部的」特徵，這些措施不受司法控制²⁹。

然而，行政實務上有愈來愈多的通令，其不自限於提醒或說明

28 Cf. DE LAUBADERE (A.), VENEZIA (J.-C.) et GAUDEMET (Y.), (註15), p. 463.

29 *Ibid.*, p. 651 et s.

現行的法律或命令，而是在現行的法秩序安排中添加新元素，特別是課予人民束縛或賦予其保障，對於此種通令應如何處理？判例的發展歷經了數個階段，現行判例區分強制性通令(*circulaire impérative*)和非強制性通令，只有後者是不予受理的，前者則是行政法院審查的對象。亦即，當通令所作之解釋違反其欲闡明之法令的意義和適用範圍，或違背法位階之固有要求時，其構成強制性通令，得針對此通令提起越權之訴；且若其上位規範本身違法，通令即使僅是重申其規定，亦是受理的且構成違法³⁰。由此可知，行政法院趨向於將以往視為內部秩序措施的部分通令，視為是對外發生效力的法規範³¹。至於有關公共服務的管理或紀律措施，則不論是屬一般性或個別性的措施，以往因被認為僅影響到微小的利益而不具重要性，故依法諺「法官不問小事」(*de minimis non curat praetor*)，淪為無救濟之區域。然而，此一證立是薄弱的，因為這些經常依附於軍事、監獄或學校機構的措施，往往對關係人帶來嚴重的後果。幸而隨著法治風氣的演進和歐洲人權法院的影響，最高行政法院近年來大幅地減少不受理的範圍，自此承認公務員得對於其考績評比提起訴訟³²、學生得針對有關配帶宗教、政治或哲學性質之標誌的學校內規以及暫時禁止入校的個別措施，請求救濟³³、軍人和監所收容人得針對關禁閉之處分，提起訴訟等等³⁴。

上述的內部秩序措施往往出自基層機關且僅影響到較小的利益，相反地，政府行為則位於行政權力的另一端，經常涉及到重大

30 CE Sect. 18 décembre 2002, Mme Duvignères.

31 有關通令的判例發展，詳見 LOMBARD (M.) et DUMONT (G.), *Droit administratif*, 6^e éd., Paris, Dalloz, 2005, pp. 44-47.

32 CE 23 novembre 1962, Camara.

33 CE 2 novembre 1992, Kherouaa.

34 CE 17 février 1995, Marie et Hardouin. 有關管理措施和紀律措施，詳見 BRAIBANT (G.) et STIRN (B.), *Le droit administratif français*, 5^e éd., Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 1999, pp. 277-279; DE VILLIERS (M.) (dir.), (註14), pp. 601-602.

的決定。其實，有關政府的使命和狹義的行政活動之間的區別，學說上有豐富的討論。無可否認地，政府的工作具有不可忽略的特殊性，但在法國，此特殊性原則上並未反應在其法制度上，特別是在訴訟制度上，是以相同的方式來對待政府和行政機關，而唯一的例外是「政府行為」，其雖出自於執行權、可能違法及損及特別利益，卻享有某種裁判豁免權³⁵。政府行為的用詞出現得很早，但判例從未定義之。依學說的分析，直到1875年左右，當一行政行為顯得受到某種政治動機的啟發，即變成政府行為，僅受國會或輿論的控制而不歸法院審理；之後，學說則改以政府與行政之區分來勾勒政府行為的特徵，因而縮減了政府行為的領域；然此標準在適用上並不明確，於是在面對僅依循列舉方式的判例，學說不再試圖證立之。由於政府行為之理論屬於舊時代的遺跡，隨著行政法院權威的確立以及其權限的擴充，此一觀念不斷地限縮。目前其被非常審慎地侷限在有關於政府和國會間之關係的行為、政府與外國強權間之關係的行為、構成戰爭事實的行為³⁶。不論是政府行為的退守，或是內部秩序措施的不斷限縮，都象徵著法治國家的進步。

在法國，全體的行政行為原則上遵守相同的合法性，且依循相同的訴訟管道。此統一性是圍繞著兩個主軸來建構：行政行為之法制度一方面並沒有依據行為是具個別的或一般的特徵而有所不同，另一方面其亦沒有因為制定行為之作者是單純的行政官員或政府成員而有所改變。也因此，越權之訴是以相同方式，用於處罰未遵守合法性的政府的規範行為以及行政機關的個別行為。當然，仍存在

35 BRAIBANT (G.) et STIRN (B.), (註34), p. 277 et p. 274.

36 有關政府行為之判例發展，詳見ODENT (R.), *Contentieux administratif*, t. I, Paris, Dalloz, 2007, p. 306 et s. 而中文文獻，可參見陳淳文，由新近判例趨勢論法國公法上的「政府行為」概念，人文及社會科學集刊，9卷4期，頁111-142（1997年）。

著一些不受理的例外情形，但這些例外得透過行為的特性加以說明，且其範圍不斷地縮小。

參、行政命令與司法審查

行政職能的行使，受到合法性原則(*principe de la légalité*)的支配。此原則意指行政當局的行動有義務遵循合法性，亦即各種位階和內容之法則的整體。合法性原則關係到行政當局的所有活動，包括個別行為和契約行為在內，而行政命令的特點在於，其本身既是合法性的來源，亦須遵從合法性原則並接受司法審查。然而，在對法國之命令違法審查的範圍和途徑進行探討前，必須留意到，在我國或德國法上支配著命令和法律間關係的法律優越原則和法律保留原則，在法國公法上有不盡相同的內涵和表現，其是否及如何影響到命令合法性的判定以及審查機制的安排，有必要先予說明和釐清。

一、命令與法律之間關係的變遷

在國家的規範活動中，相對於法律而言，命令被賦予何種地位，不僅具有實務上、也具有政治上的重要意義。在法國，一直到1958年以前，所謂「命令制定權」(*pouvoir réglementaire*)之理論，主要是受到「命令服從於法律」以及「法律領域無限制」二原則所支配：透過此一權力所制定的規定，應遵守位階較高的文本以及行政法的一般原則，且特別是，為了適用法律所制定的命令，不得扭曲此法律的規定，亦不得違反其射程範圍³⁷。但1958年憲法的制頒，雖然最終並未真正地衝擊到命令的性質及其法制度，卻在原有

³⁷ Cf. DE LAUBADERE (A.), VENEZIA (J.-C.) et GAUDEMET (Y.), (註15), pp. 566-569.

的命令與法律間的關係中，投下震撼彈。

（一）行政命令的新類型

1958年憲法的一項創新之處在於劃定法律和命令各自的領域。憲法第34條以列舉的方式來劃定法律的領域，其中一部分涉及的是由法律「訂定法則」的事項，包括公民行使自由權利之基本保障、國防義務、重罪和輕罪之劃定以及適用之刑罰、公營造物類別之創設、公務員之基本保障、企業之國有化以及公部門事業移轉到私部門之法則等等；另一部分則涉及到由法律「劃定基本原則」的項目，例如國防之一般組織、地方自治團體之行政、社會安全和勞動法、教育等等。至於命令的領域，依憲法第37條第1項之規定，凡是法律領域以外的其他事項，屬於命令的範疇。依此一新規定，在發布一般法則方面，反而是行政機關擁有一般性的權限，立法者反而僅擁有被授與的權限。1958年憲法對於規範制定權的重新洗牌，使得法律的領域變成是有限的，立法者不得再對立法領域以外的事項進行立法³⁸。

在1958年憲法下，除「法律領域無限制」之原則被打破外，「命令服從於法律」之原則，亦產生變化。對於憲法第34條明文保留給法律的領域，行政機關自不得在無明示授權下擅自介入。但對於憲法第37條以消極方式所定義的事項，因為原則上不應存在著法律，因此，相關命令的作成，不但不會是依據法律或是為了適用法律，亦無庸擔憂是否違反法律。基於這些命令相對於法律的自主性，學說稱之為「自主性命令」(*règlements autonomes*)。由於在自主性命令所介入的事項上，不存在上位法律，憲法學者在1958年憲

38 有關法律和命令的領域，詳見FRIER (P.-L.) et PETIT (J.), *Précis de droit administratif*, 4^e éd., Paris, Montchrestien, 2006, pp. 65-66; LOMBARD (M.) et DUMONT (G.), (註31), p. 34 et s.

法制定之初，多認為其位階相當於法律³⁹。

由於自主性命令的制定權限來自於憲法第34條和第37條的結合，其具有無可爭議的正統性。然而，此一新權力的來臨，並未使得傳統上為了補充法律所行使的命令制定權消失，後一權力仍意含於憲法第21條所賦予總理之「確保法律之執行」的權限中。亦即，為確保法律之執行，命令制定權仍得依據原有的方式，或是主動地或是依法律之規定而介入，因此所制定的命令，學說稱之為「適用性命令」(règlements d'application)。對於此一傳統類型的命令，有兩點補充。首先，與一些憲法學者一開始所設想的不同，在法律授權的情形下，並不用區分究竟是憲法第34條所提及之法律「訂定法則」的事項或是僅是「劃定基本原則」的事項，二者都有適用性命令介入的空間⁴⁰。其次，即使法律未明文授權，行政機關仍得自發地訂定適用法律所需的命令，且有時還構成一項義務（詳見肆、二）。而無論在何種情形，當命令介入以補充或明確化法律時，都應服從法律⁴¹。

（二）自主性命令的地位

「行政」之概念長久以來被化約為「執行法律」的理念，但1958年憲法除創造出自主性命令外，還設置了對抗立法者僭越的機制，這都讓人以為古典的命令和法律間的關係被打破，且還有學者進而主張原有對於行政職能之統一的司法審查制度已不存在⁴²。惟由後續發展來看，不論是法律和命令各自領域的劃定，或是自主性命令的「自主性」，都偏離了原先規劃的軌道。

39 有關自主性命令，參見CHAPUS (R.), (註17), p. 660 et s.; LOMBARD (M.) et DUMONT (G.), (註31), pp. 39-40.

40 CC 3 mai 1961, Droits civiques.

41 有關適用性命令，參見ODENT (R.), (註36), pp. 275-276; LOMBARD (M.) et DUMONT (G.), (註31), p. 40.

42 Cf. DE BECHILLON (D.), (註13), pp. 104-105.

在領域的保護方面，若行政法院仍持續擔任防衛立法領域的角色⁴³，1958年憲法則將保護命令事項不受僭越的任務，託付給憲法委員會(Conseil constitutionnel)⁴⁴。首先，依憲法第41條之規定，在立法過程中，若一法律提案或一修正案不屬於法律領域，政府得提出抗辯，或自2008年修憲起，國會議長亦得拒絕受理之；而如未能達成合意，交由憲法委員會作成裁決。在實務上，議長多同意政府之抗辯，因此憲法委員會少有介入的機會，且有研究顯示，此程序到後來反而多用來保護立法領域（用以對抗為干擾議事所提之修正案），或禁止立法者自我限縮其權限。其次，在法律通過但未頒布前，原本透過憲法第61條之法律合憲性審查程序⁴⁵，亦得以處罰立法者的僭越。但憲法委員會於1982年宣示，不能夠「基於立法者介入到命令領域而主張該規定違反憲法」⁴⁶，自此，第61條不能再用來對抗立法者的越權。最後，即使在法律頒布後，依憲法第37條第2項，仍得透過「敕令」(décret：由總統或總理所制定)來修改介入到屬於命令領域之事項的法律：對於現行憲法生效前介入的法律，得直接「透過經徵詢諮政院意見後所作成之敕令」為之；對於現行憲法生效後介入的法律，「只有在經憲法委員會宣告其屬命令範疇後」，才能以敕令為之。在後一情形，行政部門固然有權修改被憲法委員會「去立法化」(délégalisé)的規定，但或為求節約時間或為謹慎面對國會，在實務上則多包容法律中納入具命令性質的規定。

43 1958年憲法對於命令制定權入侵到立法領域，沒有任何安排。相關保護延續以前的方式，亦即向行政法院爭議介入到立法事項之命令。例如CE Ass. 13 juillet 1962, Conseil national de l'Ordre des Médecins判決即基於越權而撤銷某些直接違反憲法34條或是37條第2項的命令規定。參見CHAPUS (R.), (註17), p. 72; ODET (R.), (註36), p. 184.

44 以下三種機制及其發展，詳見FAVOREU (L.), *Droit constitutionnel*, 11^e éd., Paris, Dalloz, 2008, pp. 322-325; FRIER (P.-L.) et PETIT (J.), (註38), pp. 66-71.

45 依憲法第61條第2項之規定，法律在頒布前，得由共和國總統、總理、國民議會議長、參議院議長、60名國民議會議員或60名參議員提交到憲法委員會，由其宣告相關規定是否符合憲法。

46 CC 30 juillet 1982, Blocage des prix.

由上可知，1958年憲法所設立的三種監控立法權的機制，不是鮮少使用，就是在休眠狀態或是改變意含。因此，權限的分派被相對化，法律若超出其領域不會失效，而此一演變還影響到自主性命令的定位。如前所述，自主性命令表面上所具備的「起初的和不受制約」的特徵，原使得學說將在憲法第37條架構下的命令制定權視為是第二個立法權：憲法不就是將立法權分派給國會和政府、第37條的命令不就是某種形式的法律嗎？但最高行政法院排除了此種見解，其認為自主性命令就像其他的命令一樣，是應臣服於合法性審查的行政行為⁴⁷。此一立場帶來的結果是，雖然理論上自主性命令沒有服從法律的問題，但還是應該遵守所有與法律同位階的規範，特別是行政法的一般原則⁴⁸。此外，更出乎意外地，自主性命令竟與法律相遇。原因除了政府不爭議或追究立法者之僭越外，還在於憲法委員會和最高行政法院都結合憲法的其他規定，對法律領域採取擴延的觀點，例如諸多有關行政程序和訴訟之法則原屬於命令事項，但基於其對訴訟權、防禦權、自由權等的影響，而肯定了法律的介入。由於介入的法律仍是上位規範，自主性命令不得牴觸之⁴⁹。

與憲法當初所預設的相去甚遠，自主性命令的地位並未等同於法律，且在實務上，其既未能擺脫對於法律的遵守，亦未被能免於立法者的入侵。有學者指出，即使在1958年後，命令經常只在確保法律的執行，所謂的自主性命令是否果真存在令人生疑，有的恐怕只是強烈的、中等的或微弱的立法決定事項⁵⁰。總之，1958年的

47 CE 12 février 1960, Sté Eky.

48 在CE 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils判決中，最高行政法院將自主性命令維持在命令的層級，肯定其如所有的命令一樣，應遵從行政法的一般原則。有關自主性命令之定位問題，參見DE LAUBADERE (A.), VENEZIA (J.-C.) et GAUDEMET (Y.), (註15), p. 576.

49 有關法律領域的擴充，參見FRIER (P.-L.) et PETIT (J.), (註38), pp. 69-70.

50 *Ibid.*, p. 70.

「變法」並未成功，行政命令的法制度並未受到影響，不論是自主性命令或是適用性命令，都遵從法律優越原則、都臣服於屬於全體行政行為的訴訟制度。唯一的差別或許僅是在訴訟撤銷上，存在著不同的「敏感度」(susceptibilité)罷了⁵¹。

二、命令違法審查的範圍和途徑

行政機關的行為應遵守合法性原則。依此原則，行政命令如同個別行為一樣，其制定必須遵守上位規範，且受到法官的控制。行政合法性的主要來源是法律，但隨著司法審查的深化，應遵守的規範框架不斷擴充；且另應注意者，越權之訴雖構成爭議命令的主要管道，卻非其唯一的管道。

(一) 命令違「法」的範圍

在法國大革命後，法律成為行政活動的基礎和限制，在國會至上的邏輯下，法律自然構成首要的合法性來源。惟透過最高法院的解釋和補充，行政機關所應遵守的上位規範，還包括行政判例所課予之不成文法則，此外，不論是制定命令或作成處分，行政機關亦不得漠視自身所制定的法則。而較為晚近，拜憲法以及國際法（特別是歐洲法）新發展之賜，此一合法性的理念還擴展出新的維度。歸納而言，包括自主性命令在內的所有行政命令均不得違反法律、判例法則、上位命令、憲法和公約。違反法律的部分，前已提及，以下僅就其餘法源予以說明。

首先，若命令之制定應遵守上位規範，其本身亦是行政機關的內部法源，基此，下位命令不能違反上位命令。在法國，各類命令之位階，優先是依循在行政金字塔中機關的階層、自治團體的地位來決定，此外，還應考量到各機關被授權的範圍。因此，總統和總

⁵¹ 例如，對於相符性要求的嚴格程度，或對事實條件的審查強度，有些差別。參見DE BECHILLON (D.), (註13), p. 105.

理以敕令形式所發布的命令，優於其他命令，但如果法律授與某機關就特定領域擁有制定命令的權限，上級機關即不得取而代之。至於同階層之機關所發布的命令，因各自權限不同，原則上不生位階的問題，倘若發生，則應依程序或實質標準來判斷。例如向諮政院徵詢意見後所作成的敕令，因依循較為鄭重的程序，故優於其他單純的敕令；又如總理以敕令設立某個一般程序，為適用此敕令所作成的其他總理敕令，即應遵從之⁵²。

其次，在法國，判例法構成行政合法性的不成文法源，且是重要的法源，蓋整個法國現代行政法的形塑，是歸功於判例的建構。學者間對於判例規範的位階，仍有法律、憲法或超命令之效力的爭議，惟皆同意行政判例所認可的法則，在位階上是高於所有行政機關所制定之命令。其實，在法國公法上，形式或機關的標準對於決定法規範的位階而言，亦具有優勢的地位，其除如上述用於劃定各種命令之間的位階外，在決定判例法則和行政命令之間的關係中亦然：由於法官在規範制定機關中的地位，被認為優於行政機關，因而判例法則被認為優於包括最上位之命令在內的所有行政規範。適用形式標準的結果是，承認全體的判例法則都具有超命令的效力。然而，判例法則雖具優位性，卻得依法官的選擇而發生強制或補充的效果。在前一情形，除非立法者介入，否則判例法則拘束行政機關，行政法的一般原則都屬於此類強制法則；反之，行政機關得透過命令制定權的行使而予以排除⁵³。

此外，行政機關應遵守位於法秩序頂端的憲法規範。最高行政法院在1958年前即曾直接援引當時憲法序言的規定，以之作為行政

52 有關命令的位階，參見FRIER (P.-L.) et PETIT (J.), (註38), pp. 78-79.

53 有關判例法則的位階和效果，請參閱DE VILLIERS (M.) (dir.), (註14), p. 408 et s.; CHAPUS (R.), (註17), p. 111 et s.; FRIER (P.-L.) et PETIT (J.), (註38), p. 88 et s.

機關限制罷工權的基礎⁵⁴，或審查其是否違反結社自由⁵⁵。惟何謂1958年憲法下的憲法規範，一開始並不是十分確定，是嗣後透過憲法委員會的闡釋，將1789年人權宣言和1946年憲法序言的規範亦納入其中，才將「合憲性審查的基準」(bloc de constitutionnalité)予以明確化⁵⁶。因此，命令亦不得牴觸此二文本，例如限制女性入伍的敕令即被認為違反1946年憲法序言中的男女平等原則⁵⁷。然而，在實務上鮮少發生命令單純違反憲法的情形，因為二者之間經常有法律居中，於是出現一棘手的問題：當命令牴觸憲法規範卻與作為其基礎的法律相符合，應如何判斷其合法性⁵⁸？實務上所採的解決方法是，即使命令是違憲的，但因為法律在法官和憲法規範之間作成屏障，法官僅能以無效援引命令違憲之理由而予以駁回，這是著名的「立法屏障」(écran législatif)理論⁵⁹。

最後，在20世紀後半葉，國際法的角色亦有長足的發展，1946

54 CE Ass. 7 juillet 1950, Dehaene.

55 CE Ass. 11 juillet 1956, Amicale des annamites.

56 CC n° 71-44 DC du 16 juillet 1971; CC n° 73-51 DC du 27 décembre 1973.

57 CE 11 mai 1998, Mlle Aldige. 不過在某些情形下，最高行政法院認為這些文本不夠明確而不能在行政法上產生直接影響。例如，1946年憲法序言第12項有關負擔之前平等以及連帶團結之規定，因「缺乏確保其適用之明確的立法規定」而不能援引(CE 29 novembre 1968, Tallagrand)。以上有關命令是否合乎憲法規範之審查，參見FRIER (P.-L.) et PETIT (J.), (註38), pp. 40-41.

58 例如CE 28 janvier 1972, Conseil transitoire de la faculté de lettres de Paris判決所涉及的案情是，請求人立基於1946年憲法序言所明訂之公立學校教育是免費的規定，爭議依據法律授權所訂定之有關大學註冊費的教育部部令的合法性。

59 其實，承認一般法官仍得查核自法律取得違憲瑕疵的命令，似較合乎規範位階的邏輯。但若容許之，等於默示地容許其查核該命令所源自的法律本身，或至少揭發此法律的違憲性。這被認為牴觸法國傳統的權力分立觀點，且有違憲法第61條保留給憲法委員會的法律違憲審查權。有關立法屏障理論及其批評，參見CHAPUS (R.), (註17), pp. 33-34; FRIER (P.-L.) et PETIT (J.), (註38), p. 46. 惟應注意，為了避免立法屏障造成困擾，2008年修憲設立了「違憲性抗辯」機制，依憲法第61條之1之新規定，當最高行政法院或廢棄法院，在適用法律之際，對其合憲性有嚴肅的懷疑，可以提請憲法委員會對於法律是否符合憲法規範作出裁決。在宣告違憲的情形下，法律即停止作為屏障，違憲之命令於是得以被撤銷。

年憲法將條約引進到內國法秩序中，而1958年憲法則進一步將經批准和生效之條約的效力明白定位在憲法和法律之間。為確保條約的優越性，行政法院並不遲疑於適用國際法的規範，以審查命令的合法性。而近些年來，行政機關所應遵守的國際規範，特別是因為歐洲法的發達而數量激增。但相關的審查，起初亦受到上述「立法屏障」理論的阻礙，亦即，當命令的違法瑕疵是來自於法律時，法官即拒絕審查之。惟此一立場，自1989年Nicolo判決起，已經改變⁶⁰。最高行政法院自此同意附帶審查法律是否違反公約，並在法律與國際規範不相容的情形下，逕行排除法律之適用，而撤銷符合法律但違反公約的命令。由於此一審查經常是以一些重要公約中有關保護基本權利的原則為依據，故其在實際上所發揮的作用，有如法律合憲性的附帶審查，因此在法國公法上意義深遠⁶¹。

(二) 相關的審查途徑

有關命令的司法審查，不僅可以透過主要審查的管道，也可以透過附帶審查的管道為之。但無論如何，原則上都屬於行政法院的權限。

在主要審查方面，雖然自法國大革命開始，立法者即不斷地賦予普通法院某些撤銷行政行為的權限，但從未涉及到行政命令；即使到了近些年，當法律將獨立行政機關之活動的審判權移交到普通法院手中時，亦明文將具命令性質的行為排除在外。憲法委員會在其1987年有關競爭委員會的決定中即指出，法律將有關行使執行權之機關在行使公權力中所作成之決定的撤銷之訴，移轉給普通法院，有違對於行政法院權限的保留⁶²。因此，依據審判二元制的權

60 CE 20 octobre 1989, Nicolo.

61 有關命令違反公約之審查和發展，詳見BRAIBANT (G.) et STIRN (B.), (註34), pp. 239-241; FRIER (P.-L.) et PETIT (J.), (註38), p. 46 et s.

62 CC 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence.

限劃分，行政法院才是有權撤銷行政命令的法院⁶³。有關其如何透過越權之訴針對命令進行抽象審查，容於肆、分析。此處應提及的是，除越權之訴外，現行的行政訴訟類型中還有一種「宣告不存在之訴」(*recours en déclaration d'inexistence*)，透過此一管道，亦得以主要名義直接爭議命令的合法性。這是針對特別嚴重的違法性，主要是涉及到「明顯地與行政機關權力之行使無關」的行為⁶⁴。對於此類行為，即使是以越權之訴提起，行政法院有權以宣告不存在來裁決，且基於其嚴重性，起訴時間不受限制⁶⁵。

至於附帶審查方面，如同諸多國家的一般法院法官都可以於審理具體案件時，檢視應適用於其受理案件之命令的有效性，在法國，亦存在類似機制，稱為「違法性抗辯」(*exception d'illégalité*)，但情形不盡相同：在法國，雖然任何法院都可以解釋命令，原則上只有行政法院有權確認命令的違法性。因此，當此違法性是在行政訴訟中被提出，固無問題，但如是向普通法院（主要涉及民事法院）提出，原則上相關問題應被移交由行政法院來判斷⁶⁶。

首先，在行政訴訟中，違法性抗辯是兩造均得以主張的理由，其多用來支持一越權之訴，但亦得用以支持一完全之訴（例如在請求賠償之訴中主張相關命令的違法性）。作為爭議命令合法性的管道，違法性抗辯像是越權之訴，但二者有些根本的差異。首先，若撤銷之訴導致違法行為的撤銷，違法性抗辯僅導向排除其適用，因此，違法命令續存於法秩序中。其次，若撤銷之訴僅能在相當短的

63 有關撤銷行政行為之權限分配，參見NEGRIN (J.-P.), *Aspects du régime contentieux des règlements administratifs en France*, in *Etat – loi – administration: Mélanges Epaminondas P. Spiliotopoulos*, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 276.

64 CE Ass. 18 novembre 1949, Carlier.

65 有關宣告不存在之訴，參見CHAPUS (R.), *Droit du contentieux administratif*, 12^e éd., Paris, Montchrestien, 2006, pp. 211-212.

66 有關附帶審查，請參閱FROMONT (M.), (註23), pp. 280-282; ODENT (R.), (註36), pp. 252-253; GOHIN (O.), *Contentieux administratif*, 5^e éd., Paris, Litec, 2007, p. 204 et s.

起訴期間內提起，違法性抗辯原則上可以在任何時間提出，因此，即使在違法命令已擺脫被法院撤銷的威脅後，人民仍有消極抵抗的機會。最後，當命令之合法性是透過抗辯途徑來爭議時，是由對於法之實體有權限的法官來作成判斷，此導向調整行政法院內部權限的分派，亦即，地方行政法院有資格審查部長所發佈之敕令⁶⁷。

其次，當命令合法性的問題是向普通法院提出，普通法院應在行政法院針對此一先決問題(question préjudicielle)作出宣告前，先停止其審判程序⁶⁸。與個別行為之合法性判斷始終都掌握在行政法院手中不同，在歷史上，普通法院原本得以透過抗辯途徑來審查行政命令，且未曾引發是否牴觸行政與司法機關分立之原則的疑慮。但權限爭議法院於前引1923年Septfonds判決中認為，行政法院專有對命令的合法性判斷，自此否定了普通法院的相關權限（刑事法院例外，其仍自認有權自行判斷）。因此，依現行法，當民事法院認為解決其受理案件之爭紛是以命令是否合法為依據時，當事人應透過「判斷有效性之訴」(recours en appréciation de validité)，請求行政法院宣告命令之合法性。有關判斷有效性之訴的管轄權分配與越權之訴相同，而由於此類訴訟是接續於一未決的審理程序，因此被歸屬於附帶訴訟。至於針對合法性判斷之訴所作成之裁判的效力，兩個最高法院有不同見解，依廢棄法院，任何由行政法院針對行政命令之違法性所作的宣告，具有絕對的效力，民事法院的法官不得再適用之，但最高行政法院則持相反的立場，認為只有相對的效力。

1958年憲法在法律和命令的關係中所置入的變數，最終並未發生作用。在實務上，憲法委員會沒有守住自主性命令的領域，行政

67 有關命令抽象審查權之分派，見肆之引言。

68 有關判斷有效性之訴，參見NEGRIN (J.-P.), (註63), pp. 277-279.

機關的介入不論是基於法律的執行或是出於「自主的」行政活動，並不影響到行政命令的法制度。因此，全體的命令行為原則上遵守相同的合法性原則，且依循相同的訴訟管道。不論何種類別和位階的命令，除應服從憲法和國際法的上位規範外，亦不得違反在相關事項上可能存在的法律、不成文的一般原則以及上位命令；而基於審判二元制之權限劃分，對於命令合法性的確保，無論是透過何種救濟途徑，是由行政法院扮演核心的角色。

肆、行政命令與抽象審查

自19世紀中葉起，最高行政法院即開始審查行政命令，但對於命令的全面審查，仍經歷了幾個階段。一開始，基於法律授權所制定之命令(*règlements d'administration publique*)被排除於外，此類命令被認為有如授權當局親身所為，故不受審查。但自1872年起，則接受透過附帶審查的方式，來檢視其合法性⁶⁹。到了1907年的 *Companie des chemins de fer de l'est et aurtres* 判決，則進一步承認，得透過越權之訴直接予以審查，如該案的政府專員 Tardieu 所稱：「……即使是依據立法權之授權所作成，其仍然還是行政當局的作品」⁷⁰。而演進並不止於此，在機構標準的考量下，殖民地敕令(*décret coloniaux*)、敕令法(*décrets-lois*)、政府依據1958年憲法第38條請求國會授權介入法律保留事項所作成之律令(*ordonnances*)，或是總統依據憲法第16條行使緊急權力所作成之命令等等，都是越權之訴的客體⁷¹。

69 TC 13 mai 1872, *Brac de la Perrière*.

70 CE 6 décembre 1907, *Companie des chemins de fer de l'est et aurtres*.

71 以上發展階段，參見 NEGRIN (J.-P.), (註63), p. 272; LONG (M.), WEIL(P.), BRAIBANT (G.), DELVOLVE (P.) et BRUNO (G.), *Les grands arrêts de la jurisprudence administrative*, 12^e éd., Paris, Dalloz, 1999, pp. 110-111.

越權之訴成為控制命令合法性最主要、也是最強大的利器，其得無視制定者所處的高位，而將其違法產出從法秩序中徹底殲滅。然而，對於命令的違法控制，除關係到禁止在制定命令上的過度外，判例自20世紀初以來，還逐步課予採取某些行動的義務。申言之，行政機關對於合法性的遵守，由兩個要素組成：一是符合法的義務，另一是確保法之實施的義務。前者是傳統的、消極的義務，要求行政機關僅能採取不違法的措施；後者則是主動的、積極的義務，要求其應採取措施以避免法停留在未適用或違法的狀態⁷²。總括來說，命令制定權之行使，從制定到不制定、以及是否廢止和修改，都受到框架。有關命令之制定不得違法，這是越權之訴所處理的古典類型，爭議的對象是命令本身；其餘的不制定、廢止和修改，則是在行政機關有採行或廢止、修改之義務的條件下，若其拒絕利害關係人之請求，此拒絕即具有違法的瑕疵，且被視為是具命令特徵(*caractère réglementaire*)的決定⁷³，亦成為越權之訴爭議的客體，本文姑且將之統稱為提起越權之訴的「變型」。

一、原型：針對命令提起越權之訴

如貳、所述，越權之訴是用於爭議所有行政行為的訴訟管道，因此，透過此一管道直接爭議命令之合法性，其所應適用的法則，基本上與爭議個別行為所適用的法則相同，僅因命令的某些特性而有時有些差異或調整。囿於篇幅，以下僅就訴之利益、撤銷理由、裁判效果和執行等幾個重要面向，扼要說明之⁷⁴。惟應先補充的

⁷² Cf. BRAIBANT (G.) et STIRN (B.), (註34), pp. 207-209.

⁷³ 此一命令特徵非來自於行為的內容本身，而是來自於其與命令間的關聯，有學者稱之為「後果型的命令行為」(*actes réglementaires « par voie de conséquence »*)。如CE Ass. 8 juin 1973, Richard:「拒絕採行一命令性敕令之決定本身，應被視為具有命令之特徵……」，cité par CHAPUS (R.), (註17), pp. 526-527.

⁷⁴ 有關越權之訴的詳細內容，在中文文獻方面，可參見王名揚，*法國行政法*，頁676-706（1997年）。

是，在越權之訴的架構下，請求人得請求撤銷系爭行為的部分或全部，故針對命令，得僅請求撤銷某個或數個條文，或命令的全部。至於起訴期間和管轄權的劃分，原則上，有關命令的越權之訴，應在命令公布的2個月內提起，而當此命令是由總統或總理以敕令作成，或是由部長或具全國性權限之合議制機關所作成，或是此命令具有超出單一地方行政法院轄區之適用範圍時，基於此等命令的重要性，直接由最高行政法院管轄，其餘則以地方行政法院作為初審法院⁷⁵。

（一）訴之利益

越權之訴幾乎是由最高行政法院所形塑，其向來的判例政策是開放此一訴訟的近用，以使得儘可能廣泛的關係人享有此一訴訟類型的利益。然而，越權之訴並不是民眾訴訟，請求人除應具有起訴的能力以防衛其利益外⁷⁶，還應證立其具有起訴的「個人利益」(*intérêt personnel*)，此一利益的判斷是依提起訴訟之日期且原則上依據訴之聲明(*conclusions de la requête*)而非理由為之。

純就理論而言，越權之訴既然被置於維護客觀合法性的旗幟下，而合法性的維護又是屬於所有人的事務，訴之提起似不應以利益之存在為前提，且其存在反而成為某種保護違法的屏障。然而，觀諸相關判例可知，最高行政法院並無意放棄利益條件，這無疑是與避免法院過度擁塞的務實理由有關，但如同Bernard Pacteau教授所指出的，此一要求亦屬合於邏輯的考量：倘若受到行為影響者無異議，卻容許未受影響者追究之，這顯然有違情理；訴之利益的理

⁷⁵ 現規定於行政法院法典第R. 311-1條。

⁷⁶ 具有起訴能力者，包括個人、法人、甚至不具法人格的社團。其中個人較無疑問，至於法人，包括私法人，如工會、企業、社團，或是公法人，包括公營造物、公自治團體，而省長亦得爭議地方自治團體之行為（稱為«*déferé préfectoral*»）。而未申報、因此不具人格的社團，亦得爭議那些影響到依其成立宗旨所防衛之利益的行為。詳見GOHIN (O.), (註66), p. 210 et s.

論與其說是「拒絕」賦予某些人起訴的權利，毋寧說是將此權利「保留」給那些行為所針對和影響的人。惟最高行政法院雖不欲使越權之訴淪為民眾訴訟，亦不願使利益條件阻礙越權之訴的發展，於是不斷地緩和其嚴格性。主要的理念在於，為能起訴，請求人應該要被系爭行為所「觸及」(touché)，但不一定要被「損及」(blessé)；或如Hauriou所言，應基於一簡單的「被觸碰的利益」(intérêt froissé)⁷⁷。

有關越權之訴中訴之利益的判斷，引發了大量且微妙的判例。在法國，訴之利益的判斷，並未如德國之公法上權利的判斷一樣，在學理和實務上發展出一套相當完善的理論架構⁷⁸。法國最高行政法院對於訴之利益的判斷，富含著自由精神以及經驗主義的色彩，其於判決中鮮少說明、甚至有意不言明其所採的學理，因而學說雖自判例以及政府專員的結論中進行推導，企圖提出明確的標準，但如同Chapus教授所言，遭遇到體系化上非常大的困難⁷⁹。學者間的分析方法和解釋不盡相同，以下採Pacteau教授的分析架構說明之⁸⁰。

依據Pacteau教授，容許提起訴訟的資格，「應在其性質上是足夠地特別，且在其所遭受的侵襲(atteinte)上是足夠地真實」。首先，

77 以上有關利益之理論，參見PACTEAU (B.), (註22), pp. 157-159.

78 有關德國之主觀公權利理論的演變和現況，詳參Wolfgang Kahl著，林明鏘譯(註5)，頁880以下。

79 CHAPUS (R.), (註65), p. 459. 學說經常援引政府專員Théry在1971年Damasio判決中的結論(Jacques Théry conclut sur CE Sect. 28 mai 1971, Damasio)，依此結論，啟發相關判例的指導原則是：「儘可能開放給人民近用您的法院，而不陷入容許任何人來爭議任何事物的民眾訴訟中；擴大可以賦予起訴之資格之利益的圈圍，而不因而容許僅以非常次要和非常間接之方式被觸及的人民，回溯地質疑那些被直接針對之人民所接受的情況。在每一個違法性所構成之紛亂和每一個撤銷所引發之紛亂之間，您對於利益的判例因此受迫於作成困難的妥協」。然而，這些原則太過廣泛，並未建立起嚴格的標準。參見LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.), DELVOLLE (P.) et BRUNO (G.), (註71), p. 51.

80 以下分析，詳見PACTEAU (B.), (註22), pp. 159-162; 相關判決，亦請參閱LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.), DELVOLLE (P.) et BRUNO (G.), (註71), pp. 51-53; CHAPUS (R.), (註65), pp. 467-497.

在請求人之資格的特殊性方面，請求人應主張其就系爭行為的效果而言，具有「可資區別的名義」(un titre distinctif)。換言之，系爭行為是在足夠特別的條件下，觸及到請求人。基此，請求人雖不限於行為的直接相對人，但亦不應僅在於防衛一般性的社會或集體的利益。因此，單純「公民」或「某海外領地的居民」的資格是不足夠的，當他們僅以此資格起訴，未滿足利益之特別性的標準⁸¹；相同地，僅以一般消費者之資格起訴，亦是不足夠的⁸²。但在實務上，被行為觸及的方式無疑有許多，判例對此的判斷是靈活的和慷慨的。例如，地方納稅人的資格容許針對與當地預算有關的行為提起訴訟⁸³；選舉人的資格足以爭議有關選舉運作的行為⁸⁴；公共服務之使用人的資格足以對抗規範公共服務之組織和運作之條件的行為⁸⁵；居民的資格足以對抗影響到一自治團體組織結構的措施⁸⁶；災民的資格可以爭議與其有關的行為⁸⁷。相反地，有些資格太過廣

81 Cf. CE 6 octobre 1965, Marcy; CE 23 Septembre 1983, Lepetit; CE Sect. 2 avril 1954, Gaebelé. 但例外地，任何公民都可以起訴對抗一同時具一般性的和全國性的措施，例如針對有關使用商業票據之刑罰的命令(CE Sect. 12 février, 1960, Soc. Eky)，或有關濫用救濟之罰金的敕令(CE Ass. 31 octobre 1980, FEN, SNI, CGT, et Fédér. des jeunes avocats, sol. Impl.)，這是因為最高行政法院欲避免無人能爭議此等在刑事上被處罰的行為。

82 CE 26 décembre 1995, Beucher (在此判決中，涉及的是爭議禁止製藥準備以及有關有毒物質分級的命令)。但應注意，倘若是援引某類消費者之特殊利益，則是可受理的，如石油產品之消費者(CE 14 mars 2003, Migaud)。

83 CE 29 mars 1901, Casanova (在此一重要判決中，Olmato鎮的議會決定要設立一個以該鎮之預算支付酬勞之醫生的職位，由其負責免費照護所有的居民，最高行政法院推翻過去判例而指出，「系爭決議的目的是在Olmato鎮的預算中增加一支出；請求人是此鎮中的納稅人，以此資格，具有使此決議被宣告在法律上無效的利益……」。此一立場後來被擴及到縣的納稅人(CE 27 janvier 1911, Richemaond)、以及殖民地之納稅人(CE Sect. 24 juin 1932, Galandou Diouf)。

84 CE 7 août 1903, Chabot.

85 例如，判決亦很早即承認得以一公共服務之使用者的資格，爭議廢除電車在某個區停靠站之決定(CE 21 décembre 1906, Synd. des propr. et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli)或同意提高費率之決定(CE Sect. 4 décembre 1936, De Roche du Treilloy)。又如法國郵政暨電信局的使用者，得爭議一修改電信方面價格的敕令(CE Sect. 19 décembre 1979, Meyet)。

86 CE 24 février 1911, Watine-Lothé.

87 CE 10 février 1950, Gicquel.

泛，以致於不當然被接受，例如「國家的納稅人」可用以對抗稅務措施本身，但不足以對抗所有導致國庫支出的決定⁸⁸。

其次，還應檢視行為所造成之侵襲的真實性，亦即請求人應在其主張的資格中真正地受到行為的影響。這是利益理論真正的核心所在。對於提起者而言，起訴必須顯示出「實際的」(effectif)、或古典上所稱之「直接的」(direct)好處，換言之，系爭行為應以足夠直接和確定的方式影響到請求人。因而，在行為對財務或經濟的影響是難以掌握的情形下，不被認為有提起訴訟的資格，例如，針對一減輕納稅人為建造住宅而儲蓄之稅務負擔的命令，企業經營者如援引相關規定對其職業活動產生影響而請求撤銷，不被認為具有直接利益⁸⁹；又如電力的使用者亦不得爭議一增加法國電力公司負擔但未影響到電價的命令⁹⁰。相反地，一葡萄牙工人針對有關外國勞工之工作證和居留證之發放條件的修正，具有爭議此命令之合法性的利益⁹¹、一司法記者針對一減少開庭之公開性的敕令，亦得主張影響到其職業活動，而爭議此敕令⁹²。惟所謂直接或實際的好處，並不要求利益是無中介的、立即的(immédiat)，因而以露營者之名義爭議一市鎮所頒布之有關規制露營的命令，是可受理的，即使其尚未真地受到此命令的阻礙，但其可能有一天會在此市鎮的土地上紮營⁹³；相同地，旅館業者有請求撤銷一有關學校假期和日期之部

88 由於國家的納稅人為數極為眾多（例如在所得稅的情形，幾乎等同於國土上的居民），且可能引起國庫支出之措施亦多到數不清，為了不使越權之訴淪為民眾訴訟，判例始終不認為得援引國家納稅人之資格，請求撤銷可能造成國家之支出、且因而擴大請求人稅捐義務之措施(CE 13 février 1930, Dufour; CE 23 novembre 1988, Dumont)。但相反地，當請求人是以此一資格爭議一修改其作為納稅人之某一稅收之稅基或稅率的規定時，則被承認具有起訴利益(CE Ass. 16 mars 1956, Garrigou)。

89 CE 7 mars 1962, Synd. professionnel du bâtiment et des travaux publics du Loiret.

90 CE Sect. 16 novembre 1962, Association nationale des usagers de l'électricité.

91 CE 13 janvier 1975, Da Silva et Confédération française démocratique du travail.

92 CE Ass. 4 octobre 1974, Dame David.

93 CE Sect. 14 février 1958, Abisset.

令的利益⁹⁴、受僱人得對抗影響到其企業的措施⁹⁵。且這些好處並不限於是物質上，也可以是純粹精神上的利益，例如一老兵得請求撤銷一容許授予未真實參與軍事活動者老兵證的命令⁹⁶。不過無論如何，請求人仍應援引一真正屬於他自身的利益，因此，公務員原則上不得主張行為對於公共服務之公共利益造成侵襲⁹⁷；且請求人應證明依其所主張之資格，行為在事實上影響到此利益，因此，若市鎮之納稅人的資格被接受，其前提亦是行為對於預算有真實的或至少是最低的影響⁹⁸，而當涉及到「居民」的資格時，亦然⁹⁹。

此外，應注意者，判例很早即承認，賦予起訴資格的利益，除得是自然人自身的利益或是法人的利益（如公司、社團、公自治團體均起訴對抗影響到其存在、財產或地位之行為）外，亦得是集體的利益(intérêt collectif)，亦即起訴是為了防衛社團或工會之設立所欲確保的團體利益，或是為了防衛職業公會或企業董事會所旨在保護的機構利益¹⁰⁰。有關集體利益的判斷，在涉及到命令時，只要其對於團體有使命介入之領域造成一些後果，很容易被承認具有起訴利益。例如由學生家長組成的社團，可就修改教育制度之行為提起訴訟；又如公務員之工會，得針對影響其工作條件和人事僱用之命令提起訴訟；又如以改善受刑人命運為宗旨之社團，以及司法官組成之工會，得爭議一修改拘留制度以及限縮法官適用刑罰之權力的敕令。雖然不乏學者質疑，集體之訴訟可能犧牲掉個人利益之條件或有被濫用的風險，但此一訴訟已成為愈來愈通用的管道。透過此一管道，不僅一些與單純之個人相比，較具警覺性、較為堅決、且

94 CE Sect. 28 mai 1971, Damasio.

95 CE Ass. 2 juillet 1965, Synd. Indép. des cadres d'Air France.

96 CE Ass. 13 mai 1949, Bourgoïn.

97 CE Ass. 26 octobre 1956, Assoc. gén. des administrations civiles.

98 CE 22 janvier 1988, Laügt.

99 CE 22 octobre 1986, Union départementale des consommateurs des Bouches-du - Rhône.

100 CE 28 décembre 1906, Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges.

較佳武裝之守護合法性的團體，得以提起越權之訴，且人民只要組成社團（2人已足）且指定其所欲保衛之使命，即擁有另一種防衛其利益的手段¹⁰¹。

起訴資格是依個案來判斷，隨著新假設的不斷出現，判例在拒絕民眾訴訟以及放寬受理條件之間游移。雖然理論上，是否賦予起訴利益之資格，不論是針對行政命令或個別行為，是從屬於相同的條件，但事實上，就請求人所應擁有之直接的特徵和足夠特別的條件而言，無疑在命令方面較容易獲得承認。這是因為訴之利益優先是根據系爭行為的效果來判斷，因而面對具有一般性效果的命令，越權之訴自然是廣開大門，且有些類別之命令的射程範圍是如此地廣泛，幾乎導致人人都可爭議的地步。由此可知，為使越權之訴不變成民眾訴訟，最高行政法院對於定義「賦予起訴資格之圈子」的努力，特別是關係到行政命令¹⁰²。

（二）撤銷的理由

如前所述，越權之訴的傳統目的不在滿足請求人，其所涉及的是一個對於「行為」的合法性審查。檢視行政行為的合法性，這是介入到行政活動的核心，因此必須在屬於法的領域和屬於行政裁量權的領域之間，進行調節，只有前者得由法官檢視，至於後者則為適當性(*opportunité*)的問題，歸由行政機關來選擇。對於此分派線的劃定，演進並非是線狀的，但隨著行政法院審查的深化，分派線無疑是朝向有縮減適當性範圍的方向位移¹⁰³。

101 有關團體訴訟，除參見PACTEAU (B.), (註22), pp. 162-164, 另見CHAPUS (R.), (註65), p. 460 et s.

102 Cf. NEGRIN (J.-P.), (註63), p. 290; voir aussi BAILLEUL (D.), L'intérêt d'un « intérêt à agir » en matière d'excès de pouvoir, *Petites affiches*, 3 février 2003, n° 24, p. 6 et s.

103 相關演進，請參閱FRIER (P.-L.) et PETIT (J.), (註38), pp. 455-456.

依古典的分類，可能導致撤銷的違法態樣有四種：無權限、程序和形式瑕疵、濫用權力(*détournement de pouvoir*)、違反法律(*violation de la loi*)。前二者屬於外部合法性的問題；後二者為內部合法性的問題，其中濫用權力涉及的是目的之瑕疵，而違反法律除未遵守法位階、欠缺法基礎、違犯法錯誤、立基於不正確之事實外，還包括事實是否該當於法律要件、行為是否合乎比例之審查。惟最後二項審查依情形可能不受審查或有審查強度上的變化，其餘則都是法院得以審查的對象¹⁰⁴。在越權之訴中，處罰行政機關而不憂心請求人命運的初衷說明了，一直到今天仍是如此，當行政法院確認一外部瑕疵存在時，即停止對系爭行為的審理而直接撤銷之，亦即，不再追究是否有實體上的瑕疵。因此，即使在作成撤銷之判決時，實體問題並非總是獲得解決¹⁰⁵。

學說在分析撤銷理由時，一般而言，並不會特別區分行政命令和個別行為來談。不過，依Jean-Paul Négrin教授的觀察，有關命令的審查，基於此行為本身的某些特點，仍表現出一些特殊之處。首先，在無權限方面，行政行為僭越憲法保留給法律的事項，僅發生在有關命令的訴訟中。其次，在程序瑕疵方面，行政程序的要求對於命令較為寬鬆，例如命令之制定沒有附說明理由的義務，這反應在訴訟的審理上即是，不附理由原則上並不構成撤銷命令的理由。另外，在濫用權力方面，雖然請求人經常針對所有的行政行為主張此一理由，但此理由在命令方面特別難以成立。最後，在違反法律方面，法院在審查行政行為與審查基準之間的合法性關係時，一般

104 有關行政法院之審查理由，詳參*ibid.*, p. 457 et s.; RIVERO (J.) et WALINE (J.), *Droit administratif*, 17^e éd., Paris, Dalloz, 1998, p. 239 et s.

105 Cf. FROMONT (M.), (註23), pp. 166-167. 對此實務，學說有些批評，認為其阻礙了判決之有效性和可理解性。因為依形式或程序瑕疵來宣告撤銷時，其實並未責難行為的實質內容，使得系爭行為的固有合法性陷於不確定當中。且理論上，行政機關只要遵守原先被忽視的形式或程序法則，仍得重採相同內容的行為。參見BLANCO (F.), (註26), pp. 175-178.

而言，對於個別行為是採取較嚴格的相符性(*conformité*)關係的審查，對於命令則較是涉及到簡單的相容性(*compatibilité*)關係的審查；此外，法院對於在作成命令中所為判斷，經常僅進行有限審查，且此有限審查很少導致撤銷的後果¹⁰⁶。

(三) 裁判的效果和執行

先就裁判的效果而言。不論是針對行政命令或個別行為所提起的越權之訴，行政法院除不受理外，可作出駁回或撤銷的決定。若法院認為請求無理由，其作成駁回之決定，此決定僅具有當事人間的相對既判力。由於駁回之決定並不同於肯定系爭行為的合法性，故並不防礙其他請求人在遵守起訴期間的條件下，提出適切的撤銷理由而獲得勝訴；甚至在理論上，原請求人亦得基於不同於原先的撤銷理由，再次提起新的訴訟（只是恐怕難以滿足起訴期間的條件）。反之，若法院認為請求有理由，其宣告系爭行為之撤銷；因為向法院提出的合法性問題，其所涉及的不僅是行政機關和請求人間的關係，故撤銷的效力是超越當事人而對所有人發生，亦即具有對世效力。不過，判例雖然肯定「由被撤銷的行為中不能產生任何權利」¹⁰⁷，但其亦留心第三人權利的保護。一方面，其容許第三人在作成裁判前透過訴訟參加的管道，以及在作成裁判後透過第三人異議(*tierce-opposition*)的管道，來防衛其利益。另一方面，其限制撤銷對第三人的射程範圍，例如，撤銷不傳遞到與被撤銷之行為相同的決定上，且在涉及命令時，命令之撤銷不自動地擴及到適用此命令所作成的個別行為¹⁰⁸（見下段說明）。

此外，撤銷在時間上是溯及既往的，行為被視為從未存在過。

¹⁰⁶ NEGRIN (J.-P.), (註63), pp. 297-306.

¹⁰⁷ CE Ass. 10 décembre 1954, *Cru et autres*.

¹⁰⁸ 有關駁回之相對效力、撤銷之對世效力及第三人權利之保護，參見DE VILLIERS (M.) (dir.), (註14), pp. 1273-1277.

此一效力無疑產生重大後果：其不但使被撤銷之行為原所廢止或修正的行為恢復其效力，且將使適用此被撤銷之行為所作成的決定都變成是違法的，此一後果對命令而言特別嚴重，因為其在公布到被撤銷之間，可能已被反覆地適用。基於法安定性的考量，判例於是認為，若這些個別決定未在起訴期間內被爭議，即歸於確定¹⁰⁹。即便如此，由於撤銷的效果原則是徹底的，亦即是將違法行為全面、最終且回溯地自法秩序的安排中消滅，不免在某些情形下造成困境，甚至啟動新一波的訴訟。有鑑於此，最高行政法院在其設立的200年後，終於部分地推翻其一直以來的立場，而在2004年的Assoc. AC! et autres判決中宣告¹¹⁰：在對於不同公私益所造成之不利，以及限制撤銷在時間上之效力對於合法性原則和當事人訴訟權所造成之不利，依據本益分析作比較後，如認為撤銷之溯及既往可能造成「明顯過度之後果」時，可以在時間上調整撤銷的效力。自此，不論是否是在越權之訴，亦不論是否涉及命令，宣告撤銷的行政法院法官有權決定此撤銷是否以及如何具有回溯的效力¹¹¹。

而在裁判的執行方面。若行政命令或個別行為之撤銷沒有產生法空白的狀態，則案件在訴訟層面上終結，且行政機關無需採取任何行動。相反地，若造成任何法空白，行政機關即應在合理的期間內，檢視此撤銷所影響到的法狀態並填補之。惟在實務上，行政機關並非總是積極地有所作為、有時甚至有意地漠視其執行既判力的義務；至於法官，長久以來亦不關心其所宣告之撤銷的後續發展。當然，不論涉及的是明示或默示之拒絕執行，若被提交到法院，將因違反既判力而被撤銷，且此違法性還可以引發國家賠償責任。但無論如何，行政法院不得採取任何可能損及行政獨立性的約束性手

109 CHAPUS (R.), (註65), p. 1077 et s.

110 CE Ass. 11 mai 2004, Assoc. AC! et autres.

111 有關撤銷之溯及力以及其調整，詳見CHAPUS (R.), (註65), p. 1072 et s.; BLANCO (F.), (註26), p. 507 et s.

段，這是最高行政法院自行從公法之原則中推導出來的判例法則，依此法則，行政法院無權向行政機關下達指令或發布強制令¹¹²。

在過去，受理越權之訴的法官只有廢棄有瑕疵行為的權限。雖然一直到現在也是，其僅能撤銷之，而不能修改或取代之，但從最近開始，其終於擁有迫使行政機關遵循既判力的工具。有鑑於不執行既判力之處罰機制的不足，法國立法者對於傳統的行政訴訟法進行一項重大變革，其透過1995年2月8日法律，容許行政法院向行政機關發出強制令(injonction)。依此法律，行政法院得依請求人之要求，在其裁判中向行政機關指示其執行撤銷決定的明確方向，或向其發出在一定期間內執行裁判之指令。而在這兩種情形下，強制令都得附隨1980年7月16日法律所規定之滯怠金(astreinte)，若行政機關拒絕執行，課處的數額得變成是制裁性的。歸功於這些新權力，行政法院裁判的執行變得較有效率¹¹³。

二、變型：針對拒絕提起越權之訴

行政機關不能制定違法的命令，否則其所制定的命令得成為越權之訴撤銷的直接對象，除此之外，最高行政法院還在一定條件下課予其積極行使命令制定權的義務，以確保和維護合法性。這主要涉及到行政機關怠於制定命令以及怠於調整違法狀態的情形。在此等情形下，利害關係人必須先請求有權機關行使其命令制定權，若遭到明示或默示的拒絕，再針對此一拒絕提起越權之訴。

(一) 有關命令的制定

有權機關對於命令制定權的行使，原則上是有裁量餘地的，其

112 有關行政法院之「自制」(autolimitation)，詳參BLANCO (F.)，(註26)，p. 135 et s.

113 有關法官權力的強化，參見CHAPUS (R.)，(註65)，p. 1132 et s.; BLANCO (F.)，(註26)，p. 493 et s.

得自由行使或不行使之，且得在其選擇的時點頒布其認為是適當的措施，這在涉及到自主性命令時，特別是如此。甚且，這些機關還可以分割相關的規定，而將其中的一部分移交由日後頒布的其他命令來加以規範。然而，裁量權的行使卻可能造成命令制定的延遲。不論是出於政府的惡意（不贊同國會的立法）或是基於技術的因素（欲處理問題的複雜性、相關部會觀點的分歧、法律擬定上的缺陷等），都會使得法的實效性大打折扣¹¹⁴。

有關命令制定遲延的問題，在前述參、一、中提及之適用性命令的情形中特別嚴重。適用性命令類如我國之施行細則，基本上是適用法律所必要的命令，但法律通常僅止於指出由命令規定其適用方法，且當此命令未介入前法律不生效力。於是產生以下問題：行政機關不訂定或延遲訂定適用性命令，以致於作為「人民總意之表達」的法律，始終停留在無用武之地。為了預防此種現象，立法者有時直接明訂命令應頒布的時間，惟不遵守時間並未伴隨著任何處罰，因此無法解決問題¹¹⁵。為了對抗此一行政怠惰現象，文本的潛在受益人不再遲疑於向行政法院提起訴訟。長久以來，最高行政法院對此問題的答覆並不明確。其一開始似乎是傾向於否定有所謂制定命令之義務的存在，直到1951年，針對行政機關依敕令應訂定適用性命令卻拒絕訂定，始清楚承認有此一義務的存在¹¹⁶。在接下來的時間，制定義務逐漸具體化。先是在1962年出現第一個撤銷拒絕制定命令的判決¹¹⁷。在1964年，出現第一個課予國家承擔相關損害賠償的判決¹¹⁸。到了2000年Assoc. France Nature Environnement判

114 有關命令制定權之行使及其延遲原因，參見CHAPUS (R.), (註17), p. 685; SEILLER (B.), Précisions sur l'obligation d'exercer le pouvoir réglementaire, *AJDA*, 2004, pp. 761-762.

115 Cf. BRAIBANT (G.) et STIRN (B.), (註34), p. 209 et s.

116 CE Sect. 13 juillet 1951, Union des acines militaires titulaires d'emplois réservés à la SNCF.

117 CE 13 juillet 1962, Kevers-Pascalis.

118 CE Ass. 27 novembre 1964, Vve Renard.

決，判例法則最終表達如下：「除非基於遵守法國之國際義務，否則命令制定權之行使……，亦包括在一合理期間內採行適用法律所必然意含之措施」¹¹⁹。

綜觀相關判決可知，當法律或上位命令課予（或被認為課予）有權機關採行必要措施以使得此法律或命令被適用時，行使命令制定權的裁量權消失。惟首先應注意的是，一方面，制定命令之義務並非當然存在，其僅發生在因適用性命令的缺乏而使得基礎文本之適用成為不可能的情形下。1998年的Portejoie判決即指出，若此下位的部令並不是敕令之「全然適用所必要時」，並不具有作成此敕令所規定之部令的義務¹²⁰。也因此，基礎文本本身是否明文規定應制定適用性命令，並非關鍵所在¹²¹。另一方面，有時有權機關甚至應該避免作成此等命令，這是當基礎文本違法時，特別是當作為基礎文本之立法規定與國際規範不相容時，例如違背歐洲共同體指令之目標¹²²。

其次，應注意的是，當有權機關喪失其制定或不制定命令之裁量權而有行使命令制定權之義務時，其在履行其義務上，仍享有一定的期間。此一解決方法可連結到法國行政判例中經常可見的「合理期間」(délai raisonnable)的觀念，亦即，不論基礎文本是否明訂頒布的時間，命令應妥善準備才能制定，因此，只有在超出合理期間而適用性命令仍未出現時，行政機關才違反其義務。期間是否合理，是依個案判斷，依困難度得是6個月或1年不等，曾有案例因考量到政府輪替以及法律修改等因素，被認為22個月並未超過合理期間¹²³。在合理期間屆滿後，若利害關係人促請行政機關行動而未

119 CE 28 juillet 2000, Assoc. France Nature Environnement.

120 CE 30 décembre 1998, Portejoie.

121 CE Ass. 26 février 1954, Départ. de la Guadeloupe.

122 CE 24 février 1999, Assoc. de patients de la médecine d'orientation anthroposopique.

123 CE 3 octobre 1997, Assoc. nat. d'assistance aux frontières pour les étrangers.

果，得針對其明示或默示拒絕之決定，在兩個月期間內提起越權之訴；如蒙受損害，還可以請求國家賠償。

另應補充者，除基礎文本課予制定命令的情形外，當事實或法之狀況使得命令之制定成為不可或缺時，判例亦認為有權機關負有制定命令的義務。這主要是針對警察權的行使，例如市鎮長在洪水泛濫期間應規制船舶的通行¹²⁴，又如其應頒布必要的措施以中止因秩序、安全或衛生之特別危險所生的嚴重危難¹²⁵。至於基於法狀況的要求，則較為罕見，例如某機構轉型為公營造物，應在合理期間內採行必要措施以使得相關人事能享有法律所賦予的新地位¹²⁶。

最後應提及的是，與撤銷違法命令的情形相同，自1996年起，對於拒絕制定命令的撤銷，很容易伴隨著在一定期間內制定命令的強制令以及滯怠金¹²⁷，這當然有助於確保命令的制定。但透過這些措施，行政法院僅得強制行政當局採行必要之規定而能不指示其內容。1997年的Dobler判決即在撤銷拒絕且強制政府於4個月內採行適用性命令後，明白指出，「不歸屬於最高行政法院……，明確指出應介入之敕令的內容」¹²⁸。因此，有關請求制定命令之訴，一方面，其成功與否取決於合理期間的經過且從屬於法官的至高判斷，另一方面，對於行政權之缺失的「處罰」，僅表現為撤銷拒絕和強制制定。有權機關只要滿足制定必要措施之義務即可，仍保有其訂定內容的自由。換言之，對請求人而言，爭議拒絕行使命令制定權所具有的利益，其實是有限的¹²⁹。

124 CE Sect. 11 mai 1951, commune de Saacy-sur-Marne.

125 CE Sect. 23 octobre 1959, Doublet.

126 以上相關判例的發展和分析，參見CHAPUS (R.), (註17), p. 686 et s.; BRAIBANT (G.) et STIRN (B.), (註34), p. 210 et s.; ODENT (R.), (註36), p. 271 et s.

127 CE Sect. 26 juillet 1996, Association lyonnaise de protection des locataires.

128 CE 21 mai 1997, Dobler.

129 以上分析，參見SEILLER (B.), (註114), p. 765.

(二) 有關命令的廢止和修改

一命令如自始即具有違法的瑕疵，固得在其確定前（即公布後滿2個月前），直接透過越權之訴請求撤銷，但在命令確定後，仍有對抗的可能性嗎？其實，最高行政法院很早即承認，針對命令提出違法性抗辯，是沒有期間限制的¹³⁰；此外，行政機關不應該適用違法的命令¹³¹，且不適用違法命令並不構成違法¹³²。然而，這些間接的控制方式，並無法消滅命令本身及其適用的可能性，為填補此一合法性維護上的漏洞，最高行政法院另行發展出一些解決方法¹³³。

依Bertrand Seiller教授的分析，所謂的命令制定權，除起初的制定權力外，還為一派生的制定權力所補充。後者涉及的不是填補一法空白狀態，而是檢視已經確定有效的命令。針對一已經存在的命令，判例是在「維護文本」(entretien des textes)的要求下，亦即，命令與法或事實之情況不相調和的情形下，課予有權機關實施派生權力的義務¹³⁴。此一權力的行使，原可設想三種形式：撤回(retrait)、廢止(abrogation)和修改(modification)。撤回是指以回溯方式消除命令的違法性，但即使命令本身不創設任何既得權利，其卻是個別行為的基礎，而後者創設一些實際上的既得權利。基於法安定性的考量，判例從未認可為撤回構成一項義務¹³⁵。反之，廢止僅使命令對未來失效，不影響以之為基礎所承認的既得權利，再加上

130 CE 29 mai 1908, Poulin.

131 CE Sect. 14 novembre 1958, Ponard.

132 CE Sect. 3 janvier 1960, Laiterie Saint Cyprien.

133 以上間接查核方式及其缺漏，參見LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.), DELVOLVE (P.) et BRUNO (G.), (註71), p. 725.

134 SEILLER (B.), (註114), pp. 763-764.

135 惟應注意者，未確定（且假定是違法）的命令既然是可以請求裁判撤銷，因此若利害關係人在起訴期間屆滿前向行政機關請求撤回，後者即有義務為撤回之(CE 25 octobre 1985, Tabel)。

最高行政法院並不承認有所謂確保命令之維持的權利¹³⁶，因此，廢止可謂是行使派生權的優先形式。惟廢止雖無回溯力，但除非僅涉及部分廢止，否則仍引發行為的完全消失，在此考量下，另一種可能的選擇是修改，亦獲得判例的承認¹³⁷。

有關命令之廢止和修改¹³⁸的判例，可追溯到1930年的Despujol判決。此一判決已承認，當作為命令之理由的情況改變時，利害關係人得請求其作者修改之或廢止之，且在遭拒絕的情形下，得向行政法院提起越權訴訟¹³⁹。之後的判決逐步地明確化和細緻化此一解決方法的具體內容和適用範圍，詳於後述。於此須再次強調的，如同針對不制定命令所提起的訴訟一般，在此種訴訟中，是針對拒絕而非直接針對命令提起訴訟。惟請求人必須證立其自命令之撤銷（而非自拒絕之撤銷）中獲取利益，其起訴之受理與否，取決於此一利益¹⁴⁰。

1. 命令的廢止

在命令的廢止方面，還可以區分成命令自始違法 and 嗣後違法兩種情形來談。對於命令自其制定之初即有違法瑕疵的情形，最高行政法院原先的立場是有些遲疑的：一開始，其否認行政機關在起訴期間屆滿後有廢止違法命令的義務¹⁴¹；之後，原則上認為，違法命

136 CE 25 juin 1954, Syndicat national de la meunerie à seigle.

137 Cf. SEILLER (B.), (註114), p. 764.

138 此處所討論的是行政機關在何條件下有廢止或修改之「義務」而非「權能」。應指出的是，任何行政命令，即使是合法的，總是可以被原制定之機關所廢止或修正。這點與個別行為不同，對於合法的個別行政行為，若其對個人創造權利，原則上不得被廢止。參見DE LAUBADERE (A.), VENEZIA (J.-C.) et GAUDEMET (Y.), (註15), p. 675 et s.

139 CE 10 janvier 1930, Despujol.

140 CE 23 juin 1989, Bunoz; CE Ass. 20 décembre 1995, Mme Vedel et Jannot. Cités par CHAPUS (R.), (註17), pp. 690-691.

141 CE Sect. 6 novembre 1959, Coopérative laitière de Belfort.

令之作者或其上級，有依請求廢止命令的義務¹⁴²；其後又認為，在起訴期間屆滿後，廢止命令之請求不再是可受理的¹⁴³。由此可知，基本上是起訴期間的考量（即命令是否確定），影響到廢止義務之認定。直到1989年的Cie Alitalia判決，最高行政法院始明確化其立場而指出，依據行政法之一般原則，「若有權當局繫屬廢止一違法命令之請求，不論此命令是自其簽署之日起就是違法的，或是違法性是出自於此日之後的法或事實情況」，皆應滿足此一請求¹⁴⁴。

此一判決不但確立了有權當局針對自始違法之命令，不論命令是否確定，皆有依請求廢止之義務，且同時簡化了原先適用於嗣後違法之命令的判例法則。對於命令因新文本或新事實的出現而變成違法的情形，最高行政法院很早便承認有權機關有行使派生權力的義務，但條件較為複雜。依1930年Desujol判決以來所建立的古典判例，因文本所生的改變，應在該文本公布的2個月內提出廢止之請求¹⁴⁵，而在有權機關明示或默示拒絕下，再於起訴時間內向越權法官控訴此一拒絕；反之，對於因事實改變而導致合法基礎消失的情形，考量到此等改變經常是以漸進和難以察覺的方式進行，故未限制請求廢止的期間，請求可以在任何時候提出，只是當其請求被拒時，仍應遵守針對拒絕提起越權之訴的起訴期間¹⁴⁶。Cie Alitalia判決簡化和統一了此一分歧狀態，自此，利害關係人得在任何情形下、在任何時間，向有權機關提出廢止之請求。

簡言之，在今天，對於違法之命令，不論是自始或嗣後變成違法的，利害關係人都可以在任何時候要求有權之行政當局廢止之。此一全面和徹底的承認，再配合上法院得伴隨其撤銷之宣告而發出

142 CE 12 mai 1976, Leboucher et Tarandon.

143 CE Sect. 30 janvier 1981, Société Afrique France Europe transaction.

144 CE Ass. 3 février 1989, Compagnie Alitalia.

145 CE Ass. 10 janvier 1964, Synd. nat. des cadres des bibliothèques.

146 CE Ass. 10 janvier 1964, Simonnet.

在特定時間內廢止之強制令，更強化合法性的維護。另值得一提的，對於嗣後變成違法的命令，有權機關若不主動廢止，亦可能引發國家責任：行政當局理當注意到與其所制定之命令有關的情況變更，並依變更採取行動，基此，凡因違法命令之維持而受害者，即使並未請求廢止，仍得請求賠償¹⁴⁷。

2. 命令的修改

修改經常是以廢止為前提，因為其是對未來消滅某些規定而代之以一些新規定。然而，二者不能等同視之，一方面，修改得僅透過增添新規定而達成，不一定影響到有效的規定，另一方面，修改不化為廢止，因其不限於使系爭命令的某些要素消失，而得另以新規範取代之。此種積極效果令人聯想到起初的命令制定權¹⁴⁸。最高行政法院在其2003年M. Villemain判決中承認，行政機關為確保法律之適用，有修改命令的義務：「當一法律創造新的法狀態而其本身未使與之不相容的命令規定不適用時，為了確保法律之完全適用，歸屬於命令制定權自此新狀態中汲取所有的後果，而在合理期間內對於適用之規制，帶來規範位階以及特別是法之一般原則——特別是例如平等原則——之固有要求所需的修正」¹⁴⁹。

M. Villemain判決所宣示的修改義務，並不構成真正的創新，前引1930年Despujol判決已經樹立了行政機關依請求有義務廢止和修改因情況變更而成為違法之命令。Despujol判決其實開啟了兩種重建合法性的管道，只因為利害關係人通常偏好使系爭命令完全消失而非僅止於修改，判例遂忽略後一管道，前述Compagnie Alitalia判決中僅論及廢止可為佐證。即便如此，卻不宜忽視M. Villemain

147 CE Sect. 5 mai 1986, Fontanilles-Laurelli. 以上有關命令之廢止的判例發展，參見LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.), DELVOLLE (P.) et BRUNO (G.), (註71), p. 725 et s.; CHAPUS (R.), (註17), pp. 693-694.

148 Cf. SEILLER (B.), (註114), p. 764.

149 CE Ass. 28 juin 2002, M. Villemain.

判決所帶來的貢獻，因其賦予有權當局一合理期間以進行必要的修正，此無疑使得行使派生權的義務變得較為靈活。基於修改權和起初命令制定權之行使間的相似性，此一合理期間的設定，並不出人意外。在這兩種情形下，如課予有權當局立即採取行動的義務，皆非睿智的決擇。

在過去，修改的方式較未受到青睞，但其實，廢止並非都能夠達到請求人的目的，特別是當其要求擴大命令之適用範圍時，更是如此。而在近年來，修改的效用還有微妙的發展：修改之請求成為利害關係人獲得制定明確之命令規定的管道。詳言之，原則上，法院若撤銷拒絕廢止或修改之決定，其所造成的後果僅是行政機關依據法或事實的新要素重新作出決定，亦即，行政機關保有重採相同決定的可能性。然而，在司法實務上，此一原則未被嚴格遵循。在就拒絕行使派生權所提起的訴訟中，法官必須確立既存行為是在什麼地方違法，於此，所涉及的不再是應否行使命令制定權的問題，而是判斷在其實際行使中所產出之規定是否合法的問題。因為法官應就特定規定而不再僅就不特定規定之制定來作宣判，訴訟的辯論因此深層地轉變。這在涉及拒絕廢止之請求的情形下是如此，在涉及拒絕修改之請求時更為清楚。為了確立其起訴具有理由，請求人必須找出對其而言得確保合法性重建的措施；相對地，法官的撤銷決定，必然意含著存在一些可以重建合法性的增加或替代規定，而指出這些措施或規定，即暗示著有權當局負有應予以採行的義務。

在此類案件中，法官並非透過強制令，而是以實體法官的身分來界定應予採行的修正規定。雖然其可能只是重採請求人的提議，但此一權力的行使在爭議廢止之拒絕方面、更不用說在有關起初命令制定權的訴訟中，都是未見的，也因此促使部分請求人刻意「轉戰」修改的領域來爭議命令的合法性¹⁵⁰。學者間或不乏質疑法官之

150 如CE 30 juillet 2003, Syndicat des avocats de France. 以上有關命令之修改的分

作為有如指導行政機關行動的行政長官（因其迫使行政機關遵循其判決中所訂定的最低內容），但當法官所下的指導棋涉及的是過渡措施的安排時，似多肯定此一積極態度。2006年Société KPMG判決指出，「歸由被授予命令制定權之當局，基法安定性之理由，於必要時，制定新規制所意含的過渡措施」¹⁵¹；而稍後的Mme Lacroix判決則明確化實施此新義務的條件：當規制之立即適用，「就其規定之目的和效果而言，對於相關的公益或私益造成過度的侵害」，應制定過渡措施¹⁵²。在修改命令時，安排過渡措施，符合確保人民重要權利以及維護法安定性的要求¹⁵³。

越權之訴旨在保護「個別的情況」(situation individuel)，然不容否認的，當針對個別行為提起時，其較具「自利的」特徵，而針對行政命令提起時，則較具「利他的」特徵¹⁵⁴。特別是針對命令所提起的越權之訴，行政法院對於訴之利益的判斷，在放寬受理條件和拒絕民眾訴訟之間、在合法性的維護和法院的負荷能力之間拉鋸。無論如何，爭議命令的可能性是寬廣的，但相對地，法官的審查密度通常較低。而法官的權限雖僅限於撤銷違法命令，但隨著拒絕制定、廢止、修正、甚至公布命令¹⁵⁵，都成為可爭議的對象，再加上行政法院在立法者的加持下還得祭出強制令和滯怠金，在法國，透過司法途徑對於行政命令的控制，堪稱臻於完備。

析，參見SEILLER (B.)，(註114)，pp. 764-766；HUGLO (B.)，Une nouvelle obligation: celle de bien réglementer?, *AJDA*, 2009, pp. 23-25.

151 CE Ass. 24 mai 2006, Société KPMG.

152 CE Sect. 13 décembre 2006, Mme Lacroix.

153 Cf. HUGLO (B.)，(註150)，pp. 25-26.

154 NEGRIN (J.-P.)，(註63)，p. 290.

155 2003年底，最高行政法院認可了一個新原則，依此，「除非在法官的控制下有足以證立之特殊情況，行政當局應在合理期間內公布其制定之命令」(CE 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale)。

伍、反思與展望

在法國，有關行政命令的訴訟制度，究竟應依循適用於法律之制度或是適用於個別行政行為之制度，曾經左右擺盪。原因在於，作為法源，命令呈現出與法律相近的容貌；作為出自行政機關的行為，其又與個別行為系出同門。演進的結果是，命令的訴訟制度不斷向個別行為之訴訟制度看齊，最終被整合到統一的訴訟制度中，不再受到質疑¹⁵⁶。此一整合成功，無疑進一步提昇法國行政訴訟制度維護客觀法秩序的功能。且此一由行政法院行使命令合法性之抽象審查的長期傳統，亦為日後憲法委員會對於法律合憲性之抽象審查，奠定了發展的基礎¹⁵⁷。

由於行政命令不僅對外發生一般性的拘束力、數量極為可觀、且在適用順序上優先於法律，各國對於命令的監督，都不敢掉以輕心¹⁵⁸。惟如前言指出的，並非所有國家都如法國般以行政法院的抽象審查作為重要的、甚至是主要的監控機制。法國的控制機制有何優點？其他國家的司法在命令控制上扮演何種角色？與其所採的其他監督方法之間有何關聯？這些問題的思索，應有助於檢視並展望我國對於命令的控制。

一、分析／比較／檢討

法國行政法院所擁有的命令抽象審查權，被視為是對抗違法命令的有效利器，然此一司法控制機制並未在其他歐洲國家獲得普遍的承認。各國是否採納，似乎與採行司法一元或二元主義沒有特別關聯，而是與行政行為的觀點、行政訴訟制度的特徵以及其他控制機制的存在和實效性等因素，有較密切的關係。

156 Cf. NEGRIN (J.-P.), (註63), pp. 309-310.

157 FROMONT (M.), (註23), p. 360.

158 許宗力，論國會對行政命令之監督，臺大法學論叢，17卷2期，頁161（1988年）。

（一）法國制度的特色

在法國司法實務上，向行政法院爭議命令的訴訟十分豐富，原因之一是要滿足起訴條件，並非難事。如上所述，越權之訴的首要特徵在於，得提起訴訟者不限於行政行為的直接相對人或權利直接受到損害的人，舉凡所有物質或精神利益受到行為影響的人都得提起。由此導出，一方面，即使涉及的行為是適用於不確定人數的行為，即行政命令，亦是可受理的；另一方面，正因其容許所有可能因行為之適用而受到影響的人來爭議此行為，整體而言，對於行政命令，因為欠缺訴之利益而不受理的情形，是少見的。針對命令所提起的越權之訴，可稱是利害關係人近用法院中最为精采的例子。惟仍應強調的，或許在一個旨在保護主觀法狀態的訴訟體系中，針對一個賦予不確定數目之人權益的行為，難以想像單獨一人得導致其消失，而不要求這些人介入到救濟程序中；但在法國體系裡，由於當事人所具有的權利是有限的，所以並未引發困擾¹⁵⁹。

誠然，受到歐洲法的影響，同時為了回應人民的期盼，法國的越權之訴亦不斷地強化其保護請求人個別情況的功能。惟雖經歷諸多演進，今天的越權之訴仍未背離其起源時的主要特徵。學說認為，特別是基於其客觀特徵，帶來許多正面的後果，甚至有人主張在行政命令的訴訟上，法國堪稱為歐洲的榜樣。不僅近用行政法院是容易的（對訴之利益的判斷特別寬鬆，亦接受社團起訴，且費用低廉）、得對抗之命令的範圍是廣泛的（政府行為之理論未在此方面產生真正的影響，且內部秩序措施的觀念不斷退縮）、合法性的審查基準是齊備的（特別是有關違反公約之審查）、且有時審查還比個別行為較為嚴格（例如平等原則和法安定性原則對於命令的審查發揮更重要的影響）。此外，訴訟的提起還可以針對明示或默示的拒絕制定命令或是拒絕廢止或修改一既存命令，且於必要時，法

159 以上分析，參見FROMONT (M.), (註23), pp. 275-276 et 165-166.

院不遲疑於向包括總理在內的有權機關發出強制令，以期其正確地行使其命令制定權。就命令合法性控制的嚴密度而言，似乎沒有其他歐洲國家能出其右¹⁶⁰。

其實，如參、二所述，在法國還並存著附帶審查命令的管道。一般認為，抽象審查有助於法的穩定性(*stabilité juridique*)，而具體審查較適於發現違法性的適切情形。對法國學說而言，兩種機制實各有其優點，倘若僅存在後一機制，並不足以確保個人之完全保護、更遑論客觀法秩序之維護。申言之，當法院在個案中認為違法性抗辯成立，這僅招致命令在審理案件中之不適用，亦即此附帶宣告僅具相對的既判力。也因此，被宣告違法的命令仍續存於法秩序之中，對第三人全然有效。對此命令，僅仰賴行政機關之善意而指望其在被告知違法時，即自行撤回或廢止相關規定，是不切實際的。行政機關若繼續適用被宣告違法的命令，雖冒著再被法院查核的風險，但是否果真被查核，將受到請求人和受理法官之資訊來源和用心程度等變數的影響，如此一來，不但可能導致裁判的分歧，同時還造成命令在適用上的不平等。因此，相對於違法性抗辯而言，命令的直接撤銷之訴不但是一個有用的、互補的管道，且具有不可取代的價值¹⁶¹。

(二) 比較法上的觀察

針於命令所得行使的司法審查，Michel Fromont教授在其比較研究中指出，幾乎在所有的歐洲國家中，一般法官都得於審理案件之際，檢視應適用於其受理案件之命令的有效性。然而，各國在制度設計上，仍一些差異。首先，在有權進行具體審查的法院方面，最通常的安排是承認所有法官，不論其特長（民事、刑事或行政）

160 Cf. *ibid.*, pp. 359-360; ZILLER (J.), *Le contrôle du pouvoir réglementaire en Europe*, *AJDA*, 1999, p. 635 et s.

161 Cf. ZILLER (J.), (註160), p. 635 et s.

以及其層級（初審、上級審或終審），都可以附帶檢視命令的有效性。但有幾個國家例外，將權限保留給行政法院或甚至是憲法院：法國屬於前者，是貫徹其傳統之「行政與司法機關分立原則」的產物；奧地利屬於後者，明文規定於其憲法第89條。其次，大多數國家都未限定行使附帶審查的期限，但有些國家（如法、德）針對特定領域的命令（如都市計劃方面）限縮得爭議的期間。最後，幾乎所有國家都僅賦予附帶審查所宣告之違法性相對的既判力。此解決方法是合乎邏輯的，其理由在於，抗辯是由適用命令之機關來進行防衛（制定命令者通常不是訴訟當事人），且宣告之法院不一定是處理公法問題的專家¹⁶²。

至於命令的抽象審查，則非通例，僅部分國家承認或有限承認之。其中追隨法國模式而將行政命令視為行政行為、並因而使之適用與個別行為相同之救濟途徑的國家，包括比利時、義大利、瑞士、希臘等，皆承認命令的直接訴訟。而起初受到法國法影響、其後朝向主觀訴訟方向發展的西班牙和葡萄牙，則較為特別。西班牙一方面繼續承認得針對命令提起撤銷之訴，另一方面還要求，若法官在附帶審查中排除違法命令之適用，之後應將此命令之違法性問題提交到上級行政法院，由其撤銷之。葡萄牙的設計較為複雜，僅得針對區域或地方之行政機關、具行政特質之公營造物以及公共服務之特許權人所制定的命令性規定，提起越權之訴；但對於所有的命令規定，即使是出自中央行政機關，只要3次在附帶審查中被法院認定違法而基此撤銷適用此命令所作成之行為，則檢察署在獲悉後，有義務向行政法院請求宣告命令之違法性，此外，舉凡被此規範個別地觸及或在最近可能受其損害的利害關係人，亦得提起宣告之訴。另應注意，英國雖與法國分屬不同法系，但其執行機關或行政機關所訂定的命令，根本上遵循與行政機關之其他行為相同的法

162 FROMONT (M.), (註23), pp. 280-283.

則和救濟管道。原則上，所有在行政訴訟中使用之救濟管道，都可用於爭議命令的有效性，其中最常使用的是宣告之訴，可導致違法之宣告以及課予修改之強制令。愛爾蘭亦採同一解決方法¹⁶³。

然而，即使是有設置行政法院的國家，不乏以一般方式排除直接向其爭議命令之合法性者，有的是斷然否定此一可能性，如荷蘭基於法安定性和代表性民主的考量，長久以來拒絕之¹⁶⁴，而對歐洲各國行政訴訟制度愈來愈具影響力的德國，則是以有限的方式承認之。德國行政法院法第47條第1項規定：「高等行政法院在其審判權範圍內，依聲請而審判下列法規之效力：1. 依建設法規定所制定之規章，以及根據建設法第246條第2項之法規命令。2. 其他位階低於邦法之法規，但以邦法就此有規定者為限。」由此可知，規範審查是透過確認無效之訴為之，而有審查權者為高等行政法院，得爭議的客體包括依建設法規定所制定之法規（原則上排除聯邦發布之其他法規），以及當邦法律明文規定時，非聯邦當局所發布之命令（在實務上，多數邦都運用此一可能性）。至於訴之利益和起訴期間，原規定較為寬鬆，只需有「不利益」即可（類如法國法所要求之簡單的損害或被觸及的利益）且無期間限制，但為減少訟源，在1996年修法後，僅有主張其權利因法規或因其適用而受損害，或在可預見之時間內受損害者，得在法規公布後2年內提出聲請（行政法院法第47條第2項）¹⁶⁵。

163 以上採抽象審查的國家，參見FROMONT (M.), (註23), pp. 275-277 et 279-280; ZILLER (J.), (註160), p. 635 et s.

164 ZILLER (J.), (註160), p. 635 et s.

165 有關德國規範審查程序，參見FROMONT (M.), (註23), pp. 277-278；中文文獻，詳見Erich Eyermann著，陳敏等譯（註9），頁468-525。另應注意，在德國，憲法審判權與一般審判權有清楚的區分，有關聯邦或各邦層級之法規命令違憲與否的爭議，可以成為聯邦憲法法院進行規範審查的對象（不包括違法審查）。而在憲法訴願的情形，倘若人民用盡所有權利救濟途徑，認為法規命令直接侵犯其憲法上被保障的權利，或者行政法院的終局裁判侵犯其憲法上所被保障的權利，其中並牽涉法規命令之合憲性爭議，聯邦憲法法院在滿足相關法定條件下，也對法規命令享有違憲審查權。參見，黃舒芃，行政命

最後一提的，在歐洲共同體法中也存在命令抽象審查的機制。原歐體條約第230條第4項即規定：所有自然人或法人，得「對於其是相對人之決定，以及對於在命令或對其他人作成之決定的外表下所採行之與其有直接和個別相關之決定，請求救濟。」法國學說強調此條文所涉及的撤銷之訴是受到法國越權之訴的啟發，特是有關起訴的條件。實則，由於歐體法院對於「個別」影響之標準採取嚴格的定義¹⁶⁶，個人有效爭議一規範行為的可能性是微乎其微。直到里斯本條約生效，新的歐洲聯盟運作條約在其第263條第4項規定：所有自然人或法人，得在與會員國或共同體機構相同的條件下，「對於其是相對人或與其直接和個別相關之行為，以及對於與其直接相關且不需施行措施之命令行為(les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution ; a regulatory act which is of direct concern to them and does not entail implementing measures)，請求救濟。」此一修正，將共同體法與法國行政訴訟法上的受理法則，拉近許多¹⁶⁷。

(三) 綜合檢討

在法國，行政行為原則上從屬於相同的法制度，於此，個別行為和行政命令的區別，不構成根本的問題，而司法審查制度亦一體適用於二者。惟如上述，歐洲各國所採的解決方法不盡相同，有些國家保留給行政命令不同於個別行為的對待方式，且至少在原則上使其臣服於與後者不同的救濟途徑。

令，頁44-45（2011年）。

¹⁶⁶ CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann & Co Contre Commission Européenne.

¹⁶⁷ 有關法國行政法院和歐體法院之撤銷訴訟的比較，詳見BONICHOT (J.-C.) et DONNAT (F.), Comparaisons et raisons du recours en annulation devant le Conseil d'Etat et devant la juridiction communautaire, *Gazette du Palais*, 14 février 2009, n° 45, p. 23 et s. 有關歐洲聯盟運作條約第263條第4項適用上的爭議，中文文獻，可參見Wolfgang Kahl著，林明鏘譯（註5），頁892-893。

在一份對於命令制定權之控制的比較研究中，Jaques Ziller教授特別指出歐洲各國在區別法律和命令上所採之觀點的歧異及其影響。在採形式或組織觀點的國家中，由國會以外之機關所發布的一般性規範，不能是立法行為，因此被歸類為行政行為。這基本上是法國所持的觀點，而英國亦以隱含的方法採納之。在此觀點下，不論是在法國或英國，政府的規範行為臣服於與行政機關之個別行為相同的控制制度。雖然區分不同種類的命令制定權（如英國的royal prerogative是與法國的自主命令制定權相近的對應權力，英國政府得依此權力在無立法授權下作出一些決定，特別是在國家行政組織的領域中），但兩國在行政方面的最高法院都自認有權審查政府對於命令制定權的行使，即使此權力是直接派生自憲法。此外，在有關授予政府立法權方面，前述法國的律令和英國的delegated legislation，在某種意義上亦是可相比擬的：都是透過國會追認或許可而使得行政行為變成立法行為，於是得以躲避其原有的控制方法¹⁶⁸。

然而，並不是所有的國家都受到形式觀點的支配，有些國家對行政行為採取較為限縮的觀點，而將之侷限於行政機關的個別行為，且對命令行為予以區別對待，其證立的主要理由即在於命令所具有的一般的和非屬人的特質。在這些國家中，此特殊性除使得命令與法律靠攏而遠離個別行為，且對行政訴訟制度之架構產生重要影響¹⁶⁹。德國的相關制度設計即是例證。若德國對於行政行為的司法審查。比起法國而言，較為深入——甚或對人民來說較為有效率——，但其對於命令制定權違法行使的控制，則不如法國的越權之訴¹⁷⁰。

168 有關法英之比較，ZILLER (J.), (註160), p. 635 et s.

169 Cf. CAPELLE (C.), (註20), p. 261.

170 ZILLER (J.), (註160), p. 635 et s.

不過，行政行為的觀點或許可能影響到行政訴訟制度的安排，但二者間並不具有必然的關係。不乏學者指出，接受或拒絕行政法院對於命令之抽象審查，與其說是直接取決於行政命令的性質本身，毋寧說是基於對於行政訴訟所持的特殊觀點。在以行政之客觀控制為主軸的訴訟制度中，如在法國，訴訟是針對「行為」提起，請求人既是為了重建合法性而起訴，因此很容易得以爭議行政命令；相反地，在以人民權利之個別保護為主軸的訴訟制度中，則非如此。在德國，其行政訴訟是仿效民事訴訟而設計，目的在於發動兩造間的程序。因此，除了當事人在訴訟中應被置於平等的地位（例如起訴原則上停止原決定之執行）外，為了能提起訴訟，請求人必須有權利受到損害，且裁判之效力僅能關係到訴訟當事人。這些要求等於排除了針對命令之訴訟，因為一方面，此一取徑是以請求人自身的主觀權利受損為受理條件，這對於具有對世效力的行為而言，是難以證明的，另一方面，命令之效力遠超出對立兩造的範圍以外，其失效將可能影響到為數眾多者的情況，這是為立於平等地位之當事人間的訴訟所不容許的¹⁷¹。依Fromont教授的分析，由於德國行政訴訟是以主觀方式來構思，且其行政法是建立在行政當局以及其決定之對象間的二元關係上，因此，對於承認命令的直接訴訟，有其固有的困難¹⁷²。

另應注意，在完全或至少原則上排除命令抽象審查的國家中，似乎鮮少人提問附帶審查之管道是否足夠的問題。對此現象，Ziller提出兩種解釋，一是或許因為附帶審查出現的時間很早，人們可能在默默比較由國會和由執行權各自制定之規範行為後，認為仍由一般法官來保護人民對抗執行權之行為為佳，因而未因後來合

171 參見CAPELLE (C.), (註20), p. 261 ; FROMONT (M.), (註23), pp. 177-179; PAULIAT (H.), *Les convergences européennes dans le déroulement du procès administratif*, RFDA, 2008, pp. 227-278.

172 FROMONT (M.), (註23), p. 277.

憲性審查的出現而有新的想法。另一解釋是，或許是對命令制定權力所採的觀點本身抑制其去與個別行為的司法審查進行比較，亦即其認為司法審查所應控制的是行政機關，而不是執行權，對於後者，議會制度之原則和程序的控制應已足夠¹⁷³。雖是以隱含的方式，但這兩種解釋其實更一般性地指出，研究各國如何控制行政命令（或控制命令制定權），不能與其權力分立的觀點分開觀察，且除行政訴訟制度外，還應與其他控制機制的設計和實效性作整體的判斷，才不致於簡化問題的複雜性。

比較研究指出，各國在控制命令之機關和方法上，有相當的分歧性¹⁷⁴。一般而言，除一般法院的抽象或具體審查、甚至是行政責任訴訟外，在一些國家中，憲法法院或合憲性審查之機制對於命令制定權的控制，扮演著特別重要的角色，此外，國會、調解人或其他獨立機構的介入，以及行政程序的規定等等，亦是常見的安排。總體而言，法國顯得較其國家更倚仗司法的控制機制（特別是行政法院）：國會對於命令的政治控制，未曾有過其重要性；至於行政程序方面的法則，亦未發揮太大的作用，其對個別行為的要求遠高於行政命令¹⁷⁵。但即使在此國家，司法審查亦不是控制命令的唯一的管道：如前貳、一、所述，在歷史上，對於命令的最初控制，並不是裁判上的，而是行政上的，是透過訴願為之，此一管道在今天仍與越權之訴互為補充，得以用來對抗所有的行政命令；此外，在法國，還存在一個非常特別的非司法控制手段，亦即由諮政院作為政府之諮詢機關所行使的「柔性」控制，與其作為裁判官不同，其得進一步質疑政府所提出之命令草案的證立和利益。

173 ZILLER (J.), (註160), p. 635 et s.

174 詳見*ibid.*

175 Cf. NEGRIN (J.-P.), (註63), pp. 267-268.

二、我國建制行政法院命令抽象審查機制之初探

在我國，行政命令未如法國般構成得直接提起行政爭訟的客體，但亦屬於行政行為的一環，受到依法行政原則的支配。憲法第172條明文規定：「命令與憲法或法律牴觸者無效」，而行政程序法158條亦就法規命令指出，「牴觸憲法、法律或上級機關之命令」，無效。為了確保命令合乎上位規範，現行法制提供數種監督方式，惟這些機制在設計上和運作上，似不乏改善的空間。適度地和適當地賦予行政法院抽象命令審查權，或許不失為可以考慮的改革方向。

（一）命令控制的管道

在我國現制上，有關命令的監督，主要有行政、立法及司法三種監督途徑，而在行政程序法頒布後，另可加入人民參與命令制定之程序性監督。首先，基於行政一體之原則，上級行政機關對下級機關執行任務，本有指揮監督之權，且其範圍超越合法性而及於適當性、合目的性，因而自得就下級機關發布之違法命令，予以審核，甚至撤銷、廢除或命其變更等等。除了此種內部自我控制手段外，現行制度似乎對於立法監督，寄予更大的期望。有關立法權的監督，原僅透過課予行政機關送置義務來達成（中央法規標準法第7條），然相關法令並未規定如何處理違法命令，且因送置義務之履行非命令之生效要件，縱使行政機關不為之，亦不生影響。有鑑於此等缺憾，立法院職權行使法改採「廢止請求權之保留」。依該法第60條，命令送達立法院後，應提報立法院會議；出席委員認為有違反法律者，如有30人以上連署或附議，交付有關委員會審查。同法第62條進一步規定，經審查而發現有違法者，應在提報院會決議後，通知原訂頒機關更正或廢止之；若未於2個月內更正或廢止，

該命令失效。自此，立法監督在制度面上獲得強化¹⁷⁶。

對於命令的控制，還有司法機關做最後的把關。此一控制手段，可再區分是由大法官或由一般法官來行使。其實，憲法雖於第173條規定：「憲法之解釋，由司法院為之」，但僅於第171條第2項指出，「法律與憲法有無牴觸發生疑義時，由司法院解釋之」，並未明言命令牴觸憲法或法律時應如何處置。但在現行法制上，大法官得行使命令違憲之審查，殆無爭議。依司法院大法官審理案件法第5條第1項，中央或地方機關於適用命令、或人民、法人或政黨對於確定終局裁判所適用之命令，發生有牴觸憲法之疑義者，均得聲請解釋；而依同法第5條第2項以及司法院釋字第371號解釋，各級法院就其受理之案件，對所適用之命令，確信有牴觸憲法之疑義時，亦得以裁定停止訴訟程序，聲請解釋。但大法官得否審查命令是否違反法律，因憲法僅明定其有統一解釋法令之權（憲法第78條、司法院大法官審理案件法第7條），學界一直有所爭論¹⁷⁷。由釋憲實務觀之，大法官第1153次會議決議指出，當法官對命令有牴觸法律之確信時，即可不予適用，不能依司法院釋字第371號解釋提起釋憲。至於人民用盡審級救濟後，可否僅主張命令違反法律而提出聲請呢？其實，命令是否逾越母法授權或增加法律所無的限制，應屬於命令是否牴觸法律的問題，但大法官自司法院釋字第210號解釋起，建立起「行政命令牴觸母法，即為違憲」的解釋原則，將原本只是「違法」的命令解釋為「違憲」，而使自己獲取對於違法命令之違憲審查和無效宣告的正當權源¹⁷⁸。

176 以上參見葉俊榮（註11），頁428以下。

177 有關國內學者的立場，參見黃舒芃（註165），頁99註28之整理。

178 對於此一解釋原則，詳見葉俊榮、張文貞，轉型法院與法治主義——論最高行政法院對違法行政命令審查的積極趨勢，人文及社會科學集刊，14卷4期，頁531-549（2002年）。該文頁531註27引述吳庚教授之分析指出，大法官之所以將牴觸母法之命令宣告為違憲，是為因當時實務錯誤地將命令的位階置於法律，而無法對命令作是否牴觸法律的審查，大法官遂以釋憲之方法，將牴觸法律的命令，視為違憲，以導正法院判決實務容任違法命令之現象（吳

至於一般法院的法官，憲法未明示其是否享有以及如何行使命令之審查，但第80條規定法官應依據法律獨立審判。行憲之初，司法院院解字第4012號解釋即指出：「與憲法或法律牴觸之命令，法院得逕認為無效，不予適用。」而司法院釋字第38號解釋亦指出：「……所謂依據法律者，係以法律為審判之主要依據，並非除法律以外，與憲法或法律不相牴觸之有效規章均行排斥而不用。」由反面推知，如規章與憲法或法律相牴觸，法官應有權拒絕適用之。然司法院釋字第137號解釋又謂：「法官於審判案件時，對於各機關就其執掌所作有關法規釋示之行政命令，固未可逕行排斥而不用，但仍得依據法律表示其合法適當之見解。」其中「固未可逕行排斥而不用」之語，不免令人心生疑惑。不過司法院釋字第216號解釋進而言明：「……各機關依其執掌就有關法規為釋示之行政命令，法官於審判案件時，固可予以引用，但仍得依據法律，表示適當之不同見解，並不受其拘束……」。綜上可歸結出：各級法官擁有在個案中審查命令是否與憲法或法律相牴觸之權限，若認為有違法或違憲，得拒絕適用之。早期實務上即不乏排除違法命令之適用的判決，近年來行政法院的類似案例更多¹⁷⁹。

最後應指出的，行政程序法保障人民對於法規命令制定的參與權。在我國，法規命令係行政機關基於法律授權而制定，被授權之機關原則上即負有制定之義務。依據行政程序法之規定，人民參與的方式包括：對制定法規命令之提議（第152、153條），對行政機關於制定前所公告之法規命令的內容為意見陳述（第154條），以及參加行政機關依職權所舉行之聽證程序（第155條）。不論人民是提議、陳述意見或參加聽證，都屬民主精神的實踐，且對於命令內容的合法性及合目的性控制，亦具有積極的意義¹⁸⁰。

庚，行政法之理論與實用，3版，頁249-250（1996年）。

179 詳見葉俊榮、張文貞（註178），頁525以下之分析。

180 陳敏（註6），頁529以下。

(二) 命令控制的實效

我國現行的命令控制管道可謂相當完備，且從中可察覺到德國傳統法秩序理念以及美國行政程序法的影響¹⁸¹。然就其實際發揮的功效而言，除行政監督因涉及到內部自我控制，本較難期待能杜絕違法命令的產生外，外部機制的運作成效似乎亦受到不同程度的質疑。

首先，在立法控制方面，由於我國法規命令之合法性體系，在實體內容部分繼受德國法的模式，基於「議會支配」的理念，不難想像國會在監督法規命令之合法性上居於第一線的地位¹⁸²。而行政規則雖不以法律授權為依據，原無送查之必要，但現制並不區分何種命令，一律規定送立法院。惟此一控制範圍的擴大未伴隨著控制的強化。在實務上，只有使用中央法規標準法第7條所列之名稱者，才送立法院審查，於是形成行政機關刻意使用其他名稱以規避立法監督的奇特現象¹⁸³。另有研究指出，就立法院實際審查狀況來分析，大部分編列議事日程之行政命令查照案，均是交付委員會之備查案，改交付委員會審查之查照案可說是居於少數；且交付委員會審查之行政命令，審查結果又大部分是准予備查，鮮少發生通知原訂頒機關更正或廢止之情形¹⁸⁴。若非行政機關所制定之命令的品質太好，另一種可能則是，此一機制在設計或運作上仍不無改善之處。

在司法控制方面，有相關研究指出，大法官或行政法院對於違

181 有關德國、美國之影響的分析，參見黃舒芃（註165），頁75以下。

182 黃舒芃（註165），頁91。

183 吳志光，行政法，4版，頁235-236（2010年）。

184 參見范嘉倩，法院對行政命令審查之研究——以美國之相關法制為鑑，臺北大學法律系碩士論文，頁58-59（2005年）。惟近年來則出現數例，包括要求不得為逕為變更「核能發電後端營運基金收支保管及運作辦法第十四條條文」以及「教師法施行細則部分條文，並要求廢止「國家人權紀念管籌備處暫行組織規程暨編制表」等，見吳志光（註183），頁236。

法命令所進行的審查，除趨向積極之外，還帶有強烈的「形式法治主義」色彩。大法官或基於其抽象審查的特質以及對審查命令所採的迂迴路徑，不免側重於命令是否介入法律保留領域、是否有法律明確授權、是否逾越法律授權等問題，但於個案中進行具體審查的行政法院，似亦以之為榜樣¹⁸⁵。誠然，我國行政法體系高度地接納了德國法傳統中「法律中心」的法秩序理念，在德國「依法行政」的架構下，行政權的發動必須在法律規範框架下進行、受到法律的拘束；從而在我國，行政部門的命令制定權也被認為應以「法律授權」作為核心概念與法規範的控制基礎¹⁸⁶。這或許得以部分說明何以在我國，無論是大法官或行政法院，都將其審查的重心置於形式審查上。然而此種對於形式審查的側重，並未伴隨著實質審查的發展，反而衍生為某種「司法自制」的現象，不免令人失望，特別是行政法院，原本各界在行政訴訟法和行政法院組織法大幅修正後，是冀望其能真正地發揮司法監督行政的功能¹⁸⁷。

至於行政程序法，其以透明化和參與化作為法規命令之制定的結構，雖賦予人民確保命令合法性、甚至適當性的事前監督管道，惟此立法除忽略行政規則亦可能與人民發生關係外，對於違反相關規定的效果以及司法審查的可能性，亦未給予明確答案。如依美國行政程序法，程序違反構成違法，屬於法院審查的範圍；因行政命令之訂定而受有不利影響者，即得以「因政府行為而受不利影響或侵害為基礎」，取得原告適格，提起訴訟，直接挑戰法規的合法

185 詳見葉俊榮、張文貞（註178），頁515以下；陳淳文，現行行政命令合法性審查之檢討——以不利益處分所引發之司法審查為中心，收於：黃舒芃編，2007行政管制與行政爭訟，頁109、112以下（2008年）。

186 黃舒芃（註165），頁46、75-76。

187 針對大法官的審查方式，葉俊榮和張文貞教授指出，過去大法官面對黨國威權體制，故策略性地採取「形式法治主義」以換取司法解釋的空間，但如今已無此問題，應以「實質」與「程序」的法治主義的理念，嘗試與政治部門對話，以深刻論辯的司法審查。參見葉俊榮、張文貞（註178），頁548-551。

性¹⁸⁸。在我國，學說則認為，我國長期處於法規飢渴的狀態，倘使將違反事前公告及聽證程序定性為違法，將對法制作業效率和法律安定，形成不可承受之重，故應將此等程序規定理解為訓示規定，縱有違反，不影響法規命令之效力，而人民或團體，亦不得請求法律救濟；至於人民為制定法規命令之提議，本質上屬於陳情，如行政機關未依該法第153條處理，因無關乎行政處分，不得提起撤銷之訴，且因並非涉及行政法事件，亦不得提起給付之訴¹⁸⁹。除學說外，司法實務亦採取相當保留的態度，不但行政法院認為人民對於行政機關就訂定命令之請求所為的答覆，「因對其權益並無直接之損害，僅屬反射利益而已，不得聲明不服」（最高行政法院93年度裁字第385號裁定參照）¹⁹⁰，大法官對於既未具辦法之名稱與法條之形式，又未履行法規命令應遵循之預告程序，亦未會銜中央銀行所發布的法規命令，僅要求有關機關儘速檢討修正，並未宣告其違憲（司法院釋字第672號解釋參照）。因而，倘若行政機關規避程序規定，幾無救濟途徑，有學者感歎行政程序法「深化民主原則」之立法目的完全落空¹⁹¹。

（三）彌補規範秩序的缺口

誠然，控制機制的部分失靈或成效不彰，得透過強化或落實原機制而獲得改善。特別是在國內學界較為重視的立法監督方面，可

188 湯德宗，行政程序法，收於：翁岳生編，行政法（下），3版，頁119-120（2006年）。

189 陳敏（註6），頁530-531。

190 轉引自吳志光（註183），頁235註13。同書頁426指出，不乏學者認為，至少在請求訂定法規命令而遭拒絕的情形下，若符合以下條件，得提起行政訴訟：一是行政機關負有制定法規命令之義務，且經相當期間仍未履行其義務者，二是授權規範課予行政機關制定法規命令的義務至少亦具有保護個人權益之目的。因要同時具備上述要件並不容易，制定請求權自屬例外。至於若可提起，有認為採一般給付訴訟，有認為採確認訴訟，亦有認為如行政機關濫用裁量而拒絕人民之提議，屬行政處分，自得提起行政爭訟。

191 湯德宗，未依法定之法令得否作為裁判依據——大法官釋字第672號解釋評析，法令月刊，61卷5期，頁694（2010年）。

開創多元監督方式，例如可就某些或某類命令，改採同意權或聽證權之保留的方式，以利於立法權的控制¹⁹²。然考量到國會的專業能力和時間限制，要求其對命令之制定進行全面、實質的監督，有其困難，更遑論如何期待其對於不制定、不廢止或不修改命令，有積極作為¹⁹³。且如同學者所指出的，在我國，強調國會對於行政的實體規範控制，也與憲法架構和憲政實務運作有所扞格，因為我們既在傳統上不曾培養出對國會的充分信任，且在制度上保留了立法與行政間相互抗衡的空間¹⁹⁴。因此，國會的控制固有其價值，但本文以為，有鑑於我國行政權十分強大、甚至獨大，進一步強化司法對於命令之實質和程序的合法性控制，極具正當性和重要性。對此，原有的司法控制以及或可透過司法控制予以確保的程序控制手段，當然可以因為法官深化其審查而發揮較大的作用。但除「力道」的強化外，以法國行政法院所擁有的命令抽象審查權作為另一個反思的起點，適度地開鑿行政法院介入的「通道」，以擴張其維護客觀法秩序的功能，似非不能考慮的選項之一，且若能設計和配套得宜，還能彌補現制的缺口。

如前所述，現行對於命令的司法審查管道，只有大法官得於審查命令是否違反憲法，或從違憲角度切入來審查命令是否違反法律

192 在現行法中，例如政府採購法第104條第2項規定應送立法院審議，即採同意權保留之方式。有關國會的監督方式，依控制效力之強弱，約有「同意權之保留」、「廢止請求權之保留」、「國會聽證權之保留」、「單純送置義務之課予」四種。採行何者，涉及立法政策的考量，一般而言，若急需命令以資適用，宜採「廢止請求權之保留」或「單純送置義務之課予」之事後監督模式。而命令內容對人民權益之影響程度、對基本權利之衝擊程度以及可能引起政治衝突之激烈程度，均可作為採取強烈或溫和監督模式之判斷基準。有關此四種模式，詳見許宗力（註158），頁139以下，而採何種模式之判斷基準，特別參見頁162，註80。

193 葉俊榮（註11），頁432即強調國會監督的困難，以及可能帶來諸如利益團體的干預以及延緩行政效能的負面影響；同文第439頁亦指出，在我國實務上，主管機關拖延訂定命令以致於影響法律之執行的情形，十分普遍。

194 黃舒梵（註165），頁75。

後，宣告其無效。而各級法院法官對於牴觸憲法或法律的命令，則如同錢建榮法官曾指出的，「固然得於個案中拒絕適用，惟其亦僅於個案中發生效力，即使於終審法院亦拒絕適用，在我國非採強制先例拘束原則之實務，除非作成我國另一特有制度——判例，否則仍不致發生一般對世之效力，如此反有害法安定性之維護」¹⁹⁵。錢法官所希望突破的是法官聲請釋憲的限制，惟其所提出的問題正是一般法院之具體審查所共通的。對於牴觸憲法或法律的命令，各級法官即使可於個案中逕自拒絕適用，但既不能直接宣告其無效，亦無庸或不能提出聲請，以致於該命令在法秩序中繼續有效。如果另一位法官認為該命令合憲或合法而適用之，將造成裁判的分歧，這不但符合法安定性的要求，且有違在適用命令上的平等原則。對此問題，或可透過洞開大法官受理的大門而獲得解決，惟命令多如牛毛，大法官在法律違憲審查之外，是否仍有足夠餘力從容應付，實令人懷疑。且在法理上，不論是命令的違憲或違法審查，是否應由大法官主掌，亦不無討論的空間¹⁹⁶。

吳庚教授認為，在無其他法院得對行政命令進行抽象審查的情況下，若否定大法官可以介入命令違法審查，會在我國的規範秩序中留下一個缺口¹⁹⁷。本文以為，為填補此規範秩序的缺口，特別是慮及繫屬大法官的困難度和時效性（人民必須先用盡審級救濟），在大法官與行政法院之間做適當的分工，而適度地賦予後者針對命令行使抽象審查的權限，在立法政策上應不失為可以考慮的方向。如前曾提及的，我國行政訴訟制度所大力仿效的德國，亦有限地承認之。查該國學說，行政法院之法規審查程序並不違反權力分立原則：「對行政之司法審查，為行政法院之事務。在行政從事制定法

195 參見錢建榮法官（司法院釋字第636號解釋）釋憲聲請之補充說明書。

196 例如有學者主張，命令的形式審查應屬立法院之權限，而具體審查應由行政法院主導，見陳淳文（註185），頁110-111、125-129。

197 吳庚，憲法的解釋與適用，3版，頁366（2004年）。

規之活動時，亦無不同」¹⁹⁸；且認為，在單一程序中，撤除為數眾多之行政機關決定的基礎，可以避免許多個別之訴訟程序，而給與個人更有效、更合理以及更經濟的權利保護；此外，作成具有普遍拘束力的法規審查判決，亦可避免在個別訴訟程序中發生判決歧異，符合法治國家的要求¹⁹⁹。此一抽象審查機制，除其所具有之避免裁判分歧以維護法安定性，以及即早於上游清除違法來源而一勞永逸等優點是法、德等採行之國家所共同承認者外，在我國，可能還具有象徵性的意義。我國行政法院在面對行政權時，似有過度尊重而自我限縮權限的傾向，如果能明示授與其對命令的抽象審查權，不但在制度上亦在心理上強化其作為行政合法性維護者的角色，應當有助於其全面深化其審查。

行政訴訟法第1條在「增進司法功能」外，將「保障人民權益」與「確保國家行政權之合法行使」並列為行政訴訟之目的，後一目的應可為賦予行政法院抽象命令審查權，提供部分正當性的基礎。但無可否認的，我國行政訴訟制度的整體設計，不同於法國模式般地圍繞在「合法性控制」上發展。正如學者在針對我國是否及如何建立新的訴訟型態時所提醒的，「……人民權利保障屬我國行政訴訟制度之核心功能。惟憲法第16條並不禁止立法者為了因應現代社會各種新興挑戰，透過法律擴張行政法院維護客觀法秩序之功能。然而……仍應考量到……行政法院的功能荷能量自有其極限，若過度擴張其維護客觀法秩序之功能，則勢必對其核心功能成排擠效應，甚至因訴訟泛濫拖垮行政法院。……自應謹慎妥為規劃，以免行政法院之功能因量變而生質變」²⁰⁰。因而，至少就短期而言，一起步即仿效最極致的法國模式，恐有困難且不一定有其實益。

198 亦即，問題毋寧在於以何種形式給予權利保護，而依通說，無須就一般情形為主要審查，附帶審查即可充分符合基本法第19條第4項之要求。參見Erich Eyermann著，陳敏等譯（註9），頁473-474。

199 參見Erich Eyermann著，陳敏等譯（註9），頁474-476。

200 盛子龍（註2），頁31。

考量到我國目前的行政訴訟制度以及司法資源，可以設想的方法是有限度的引進，或透過事項列舉的方式（如德國之規範審查程序），或以經附帶審查宣告違法作為發動抽象審查程序的前提（西班牙或葡萄牙之特殊機制），或可考慮僅授予特定公益社團有提起相關訴訟的資格²⁰¹。至於哪些命令可以成為審查的客體、是否採訴願前置主義、訴訟類型為何（法國的撤銷之訴或德國的確認之訴，或建制特殊類型），是否包括不制定、不廢止或不修改（以及其相對應的訴訟類型）²⁰²、行政法院管轄權的分配、起訴期間的限制、訴之利益的認定、違「法」的範圍、訴訟參加、甚至發布命令之機關可否提起上訴……等細部問題，都有待大方向確定後，進一步討論與研擬。

201 對於有限度的引進，本文初步的想法是，在「無中生有」的起步階段中，似可延伸我國行政訴訟法第9條公益訴訟之精神，先以個別法律，就特定事項，賦予特定公益團體，得向行政法院提起抽象審查之訴，例如於個別的環保法律中，明訂環保團體基於維護公益之目的，得針對適用該法所訂定之命令是否違反程序或實體規定，甚或針對依請求而不制定、不廢除或不修改相關命令之明示或默示決定，向行政法院爭議其合法性。再依實行結果，評估是否及如何擴充命令抽象審查之機制。但由於我國行政訴訟法並未有關於規範審查之規定，似有必要參考德國行政法院法第47條，增訂行政法院依法律之規定，對於相關行政命令擁有抽象審查權，且進一步設計訴訟類型和相關配套。

202 德國學說對於制定規範之訴的討論，除「真正的訂定規範之訴」（針對行政機關對其有義務訂定之法規範的全然不作為）外，亦及於「非真正的訂定規範之訴」，即人民針對既存規範之內容上之不完全或有瑕疵、甚至缺漏，請求補充或修正。詳參程明修（註8），頁130以下。

參考文獻

1. 中文部分

- Erich Eyermann著，陳敏等譯（2002），德國行政法院法逐條釋義，台北：司法院。[Eyermann, Erich (2000), *Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar*, 11. Aufl., München: C.H. Beck.]
- Wolfgang Kahl著，林明鏘譯（2011），德國與歐盟行政法上主觀公法上權利之現況、演變及其展望，臺大法學論叢，40卷2期，頁877-906。[Wolfgang Kahl (2011), *Das subjektive öffentliche Recht im deutschen und europäischen Verwaltungsrecht – Stand, Entwicklung, Perspektiven*. 收於：臺大法學論叢40卷2期網頁，<http://www.law.ntu.edu.tw/ntulawjournal>。]
- 王名揚（1997），法國行政法，北京：中國政法大學。
- 吳志光（2010），行政法，4版，台北：新學林。
- 吳庚（1996），行政法之理論與實用，3版，台北：自版。
- （2004），憲法的解釋與適用，3版，台北：自版。
- 林明鏘（2009），歐盟行政法——德國行政法總論之變革，台北：新學林。
- 范嘉倩（2005），法院對行政命令審查之研究——以美國之相關法制為鑑，臺北大學法律系碩士論文。
- 盛子龍（2002），行政訴訟法上「請求法規命令制定之訴」初探，收於：翁岳生編，當代公法新論（下），頁193-213，台北：元照。
- （2002），第1條 立法宗旨，收於：翁岳生編，行政訴訟法逐條釋義，頁25-34，台北：五南。
- 許宗力（1988），論國會對行政命令之監督，臺大法學論叢，17卷2期，頁139-162。

- 陳英鈴（2000），撤銷訴訟的訴權——個人權利保護與法秩序維護之爭，收於：台灣行政法學會編，行政法爭議問題研究（下），頁981-1008，台北：五南。
- 陳敏（2011），行政法總論，7版，台北：自版。
- 陳淳文（1997），由新近判例趨勢論法國公法上的「政府行為」概念，人文及社會科學集刊，9卷4期，頁111-142。
- （2008），現行行政命令合法性審查之檢討——以不利益處分所引發之司法審查為中心，收於：黃舒芃編，2007行政管制與行政爭訟，頁105-169，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。
- 陳清秀（2011），行政訴訟法，4版，台北：元照。
- 湯德宗（2006），行政程序法，收於：翁岳生編，行政法（下），3版，頁25-155，台北：元照。
- （2010），未依法定之法命令得否作為裁判依據——大法官釋字第672號解釋評析，法令月刊，61卷5期，頁680-700。
- 湯德宗、吳信華、陳淳文（2005），論違憲審查制度的改革——由「多元多軌」到「一元單軌」的改制方案，收於：湯德宗編，憲法解釋之理論與實務（第四輯），頁523-592，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。
- 程明修（2005），請求行政機關訂定法規命令之行政訴訟，收於：司法院編，行政訴訟制度相關論文彙編（第5輯），頁125-174，台北：司法院。
- 黃舒芃（2011），行政命令，台北：三民。
- 葉俊榮（2006），行政命令，收於：翁岳生編，行政法（上），3版，頁390-474，台北：元照。
- 葉俊榮、張文貞（2002），轉型法院與法治主義——論最高行政法院對違法行政命令審查的積極趨勢，人文及社會科學集刊，14卷4期，頁515-559。
- 劉宗德、彭鳳至（2006），行政訴訟制度，收於：翁岳生編，行政

法（下），3版，頁351-555，台北：元照。

蔡志方（1982），法國行政救濟制度研究（上），憲政時代，7卷4期，頁28-46。

——（1983），法國行政救濟制度研究（下），憲政時代，8卷4期，頁59-82。

2. 西文部分

Bailleul, David (2003), L'intérêt d'un «intérêt à agir» en matière d'excès de pouvoir, Petites affiches, 3 février, n° 24, p. 6 et s.

Blanco, Florent (2010), Pouvoirs du juge et contentieux administratif de la légalité, Aix-Marseille: Presses universitaires d'Aix-Marseille-PUAM.

Bonichot, Jean-Claude et Francis Donnat (2009), Comparaisons et raisons du recours en annulation devant le Conseil d'Etat et devant la juridiction communautaire, Gazette du Palais, 14 février, n° 45, p. 23 et s.

Braibant, Guy et Bertrand Stirn, (1999), Le droit administratif français, 5^e éd., Paris: Presses de Sciences Po et Dalloz.

Capelle, Caroline (2008), Acte administratif et justice administrative en Europe, RFDA, pp. 258-263.

Chapus, René (2001), Droit administratif général, 15^e éd., t. I, Paris: Montchrestien.

——（2006），Droit du contentieux administratif, 12^e éd., Paris: Montchrestien.

De Béchillon, Denys (1996), Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l'Etat, Paris: Economica.

De Laubadère, André, Jean-Claude Venezia et Yve Gaudemet (1994), Traité de droit administratif, 13^e éd., t. I, Paris: LGDJ.

De Villiers, Michel (dir.) (2003), Droit public général, Paris: Litec.

- Dupuis, Georges et Marie-José Guédon (1993), *Droit administratif*, 4^e éd., Paris: Armand Colin.
- Favoreu, Louis (2008), *Droit constitutionnel*, 11^e éd., Paris: Dalloz.
- Frier, Pierre-Laurent et Jacques Petit (2006), *Précis de droit administratif*, 4^e éd., Paris: Montchrestien.
- Fromont, Michel (2006), *Droit administratif des Etats européens*, Paris: PUF.
- Gohin, Olivier (2007), *Contentieux administratif*, 5^e éd., Paris: Litec.
- Huglo, Benjamin (2009), Une nouvelle obligation: celle de bien réglementer?, *AJDA*, pp. 20-27.
- Lombard, Martine et Gilles Dumont (2005), *Droit administratif*, 6^e éd., Paris: Dalloz.
- Long, Marceau, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé et Genevois Bruno (1999), *Les grands arrêts de la jurisprudence administrative*, 12^e éd., Paris: Dalloz.
- Négrin, Jean-Paul (1998), Aspects du régime contentieux des règlements administratifs en France, in *Etat – loi – administration: Mélanges Epaminondas P. Spiliotopoulos*, pp. 267-310, Bruxelles: Bruylant.
- Odent, Raymond (2007), *Contentieux administratif*, t. I, Paris: Dalloz.
- Pacteau, Bernard (2005), *Contentieux administratif*, 7^e éd., Paris: PUF.
- Pauliat, Hélène (2008), Les convergences européennes dans le déroulement du procès administratif, *RFDA*, pp. 225-233.
- Rivero, Jean et Jean Waline (1998), *Droit administratif*, 17^e éd., Paris: Dalloz.
- Seiller, Bertrand (2004), Précisions sur l'obligation d'exercer le pouvoir réglementaire, *AJDA*, pp. 761-766.
- Ziller, Jaques (1999), Le contrôle du pouvoir réglementaire en Europe, *AJDA*, p. 635 et s.